分　类　号：D996.6　　单位代码：10183

研究生学号：2021222102　　密　　级：公开

硕士学位论文

（学术学位）

气候变化下国际投资条约的应对与完善

The Response and Improvement of International Investment Treaties Under Climate Change

作者姓名：陈长文
专　　业：国际法学
研究方向：国际法
指导教师：王彦志 教授
培养单位：法学院

二〇二四年六月

中国知网 https://www.cnki.net

气候变化下国际投资条约的应对与完善

The Response and Improvement of International Investment Treaties Under Climate Change

作者姓名：陈长文
专业名称：国际法学
指导教师：王彦志 教授
学位类别：法学硕士
答辩日期：2024 年 5 月 28 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

气候变化下国际投资条约的应对与完善

气候变化问题已经成为人类共识，气候变化导致一些极端现象频繁发生，例如极端天气、冰川融化引起海平面上升。气候变化导致粮食减产从而引起气候变化难民数量大量激增，滋生社会骚乱，严重影响人类生活水平和稳定。为了更好解决气候变化问题，统筹各国力量，国际上陆续缔结了《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》等与气候变化相关的国际条约。但相关条约并未让各缔约国很好的履行相关的气候变化保护义务，积极实施气候变化保护措施。气候变化保护相关的条约与国际投资条约因宗旨与目的不同，使东道国在气候变化背景下加大了被诉风险。国际投资条约在诞生之日起，作为资本主义国家保护自身投资者的工具，加上当时人们气候变化保护意识薄弱，国际投资条约沦为资本主义国家资本扩张的工具。国际投资条约在东道国公共利益与投资者私人利益严重倾斜，使东道国采取措施抑制气候变化时极易违反国际投资条约中的投资保护义务，从而面临赔偿的风险。国际投资条约的保护偏向体现在条约的各个方面，在序言中一味强调促进投资，强调投资者的投资权利而忽视其保护气候变化的义务。在实体方面，国民待遇、最惠国待遇、公平公正待遇条款和征收条款的模糊性规定，导致其在具体适用范围边界不清，从而造成投资者滥用上述条款规定最后造成东道国权益受损。在程序方面，国际投资仲裁制度近年来也争议不断，体现在仲裁庭偏袒投资者不公正裁判。裁判欠缺连续性，出现相同案件二种不同裁判结果，同时透明度欠缺引发仲裁庭公信力危机。国际投资仲裁的案件审理时间长、应诉成本高加重了发达国家与不发达国家之间的不公平，投资者利用该点把投资仲裁作为迫使东道国妥协的工具，这一现象与仲裁制度设立初衷背道而驰。投资仲裁设立初衷本是为了平衡投资者弱势地位与东道国强势地位，避免投资者在投资者被不公平对待，同时给予投资争议公平公正解决。归根结底，上述现象的产生，与国际投资条约设定不合理，欠缺气候变化因素的考量密切相关。为了适应现实发展，促进气候变化保护，实现人类社会的可持续发展，应对国际投资条约进行改革，减少其与气候变化保护相关条约的矛盾和冲突，凝聚东道国各国力量一同保护全球气候变化。具体措施表现为，在序言中纳入气候变化保护，奠定投资条约的“绿色”基调。对先前的模糊用词的国民待遇、最惠国待遇、公平公正待遇和征收条款，重新限定其适用范围，采取列举式方法正面划定其的适用情况，减少其滥用几率，在条款规定中纳入气候变化因素考量。在投资条约的权利和义务章节中重申东道国的公共利益规制权和投资者保护气候变化义务。而对于程序上，对投资仲裁制度进行改革，增加其透明度，设立审理期限，

中国知网 https://www.cnki.net

设立上诉机构并在合适时机设立常设仲裁法庭，确保对具体案件可以做到更好的公平公正。

关键词：国际投资条约 投资条约仲裁 气候变化 东道国规制权

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The Response and Improvement of International Investment Treaties under Climate Change

The issue of climate change has become a common understanding of human beings. Climate change causes some extreme phenomena to occur frequently, such as extreme weather and sea level rise caused by melting glaciers. Climate change has led to a decrease in food production, resulting in a large increase in the number of climate refugees, breeding social unrest, and seriously affecting human living standards and stability. In order to better solve the climate issue and coordinate the efforts of all countries, the international community has issued a series of climate-related international treaties such as the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. However, the introduction of relevant treaties has not made the States parties well fulfill the relevant climate protection obligations and actively implement climate protection measures. Climate protection-related treaties and international investment treaties increase the risk of litigation in the context of climate change due to their different purposes and objectives. Since the birth of the international investment treaty, as a tool for capitalist countries to protect their own investors, coupled with the weak awareness of climate protection at that time, the international investment treaty has become a tool for capitalist countries to expand capital. In the international investment treaty, the protection of public interest and private interest of investors is seriously tilted, and the host country is easy to violate the investment protection obligation when taking climate protection measures, thus facing the risk of compensation. The protection bias of the international investment treaty is reflected in all aspects of the treaty, which emphasizes the promotion of investment in the preamble and the investment rights of investors while ignoring their obligation to protect the climate. In terms of entity, the vague provisions of national treatment, most-favored-nation treatment, fair and equitable treatment clause and expropriation clause lead to unclear boundaries in the specific scope of application, which leads to the abuse of the above provisions by investors and finally damages the rights and interests of the host country. In terms of procedures, the international investment arbitration system has also been controversial in recent years, which is reflected in the unfair judgment of the arbitral tribunal

中国知网 https://www.cnki.net

favoring investors. There is a lack of continuity in the judgment, two different decisions in the same case, and the lack of transparency has led to a crisis of credibility of the arbitral tribunal. The long trial time and high cost of international investment arbitration cases aggravate the inequity between developed and underdeveloped countries, and investors use this point to use investment arbitration as a tool to force the host country to compromise, which runs counter to the original intention of the arbitration system. The original intention of investment arbitration is to balance the weak position of investors and the strong position of the host country, to avoid unfair treatment of investors, and to provide a fair and just settlement of investment disputes. In the final analysis, the above phenomenon is closely related to the unreasonable setting of international investment treaties and the lack of consideration of climate factors. In order to adapt to the actual development, promote climate protection and realize the sustainable development of human society, the international investment treaty should be reformed to reduce the contradictions and conflicts between it and climate protection-related treaties, and gather the strength of host countries to protect the global climate. Concrete measures include the inclusion of climate protection in the preamble to establish a "green" tone in the investment treaty. Relimit the scope of application of the previously vague terms of national treatment, most-favoured-nation treatment and expropriation clauses, adopt an enumeration method to positively delineate their application, reduce the possibility of abuse, and incorporate climate factors into the provisions of the provisions. The rights and obligations chapter of the investment treaty reaffirms the public interest regulatory rights of host countries and the climate protection obligations of investors. In terms of procedures, the investment arbitration system should be reformed to increase its transparency, set up a trial period, set up an appellate body and set up a permanent court of arbitration when appropriate, so as to ensure better fairness and justice in specific cases.

Key words： International investment treaties, investment treaty arbitration, climate change, regulatory right of host country

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

引言.....1
(一)问题的提出.....1
(二)选题背景及意义.....1
(三)研究综述.....2
(四)研究方法.....5
一、气候变化对国际投资条约提出的挑战.....7
(一) 气候变化引起的次生灾害造成重大损失.....7
(二) 国际投资条约与环境保护条约矛盾日益明显.....8
(三) 气候变化制约着国际投资条约的适用.....8
二、 现有国际投资条约应对气候变化问题不足的诱因.....10
(一)国际投资条约对气候变化问题含糊不清.....10
(二)国际投资仲裁庭对气候变化问题裁决失衡.....21
三、 国际投资条约应对气候变化问题的改进措施.....24
(一) 国际投资条约明确回应气候变化问题.....24
(二) 纠正国际投资仲裁庭的裁决失衡状态.....30
结语.....34
参考文献.....36

中国知网　https://www.cnki.net

引言

（一）问题的提出

根据联合国贸易与发展会议（UNCTAD）公布的数据，截止在 2021 年，投资者以东道国采取环境保护措施违反国际投资条约为由提起投资者与国家间争端解决（ISDS）仲裁案件达 175 件。化石染料行业的投资者更是针对不同类型的国家行为提起了至少 192 起 ISDS 案件。在过去十年里，可再生能源行业投资者提出的 ISDS 案件也出现并激增，已知案件有 80 起。[1]近年来，投资者以东道国保护环境措施违反国际投资协定为由而诉诸仲裁的案件愈发频繁。气候变化及其所带来的负面影响越来越受到公众关注，《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》《巴黎协定》等条约不断推出，意在规定相关国家义务，促进环境保护。仲裁案件数量的增加表明环境保护条约与国际投资条约二者间存在着矛盾，东道国在实施保护环境措施时极易被投资者起诉，如不及时解决两类条约间的矛盾，将会使环境保护条约形同虚设，条约目标难以实现，最终难以实现人类的可持续发展。而解决该问题的关键，就在于投资条约的改革与更新换代，采取更直接的国际投资协定改革措施，减轻 ISDS 风险，并为各国采取紧急气候变化行动创造必要的政策空间。

（二）选题背景及意义

气候变化问题已经成为人类共识，气候变化导致一些极端现象频繁发生，例如极端天气、冰川融化引起海平面上升。气候变化导致粮食减产从而引起气候变化难民数量大量激增，滋生社会骚乱，严重影响人类生活水平和稳定。气候变化现如今已成为全球重视的社会问题，气候变化问题急需一种全球性的治理机制，需要各国的共同努力。为应对气候变化，国际社会做出了许多努力，如缔结了《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》《巴黎协定》等一系列多边条约。在国际投资领域，近几年与气候变化问题有关的国际投资仲裁案件数量不断增长，这些案件都围绕着东道国针对气候变化采取有关应对措施与国际投资条约规定的投资保护义务之间的冲突展开，大部分案件都以东道国失败告终。这严重打击了东道国采取措施应对气候变化问题的积极性，造成了政府规制的“寒蝉效应”，影响了有关气候变化国际立法目的的实现，导致气候变化问题未能得到有效解决，最终影响全人类的生存。此选题的目的和意义就在于针对此种现象，提出国际投

[1] See UNCTAD, *International Investment in Climate Change Mitigation and Adaptation Trends and Policy Developments*, 2022, p.23.

中国知网 https://www.cnki.net

资协定的具体改进措施，从而消除东道国采取有关气候变化措施而被投资者以违反投资保护义务提起仲裁的风险，使东道国气候变化规制行为与投资保护义务二者平衡，促使气候变化友好型投资，最终实现人类的可持续发展。

（三）研究综述

1.国内研究现状

国内学者主要以程序和实体两方面提出国际投资条约的改进。在程序方面，学者将主要矛盾对准国际投资仲裁机制。刘万啸在文章[2]指出，现有的争端解决机制使东道国处于两难之地，即东道国为履行减排义务采取的规制措施易被投资者以违反国际投资条约为由提起仲裁，从而面料承担赔偿的风险。这一机制打击了东道国履行减排义务的积极性，对世界经济和环境的可持续发展起到阻碍作用。面对这一困境，他指出我国现有或将有投资协定应该明确约定以用尽当地救济作为提起仲裁的前提条件。在协定中订入公共安全、环境等公共政策条款，并将此类事项排除在国际仲裁事项之外，将调解作为解决投资争端的必经程序，以此减东道国被仲裁的风险。李坤海[3]认为国际投资仲裁制度出现协调的困境在于仲裁规则缺乏明确的经济目标与公益目标融合机制。对此，其提出投资仲裁在改革中必须承认东道国为应对气候变化而采取措施的管制权，同时补充专业仲裁员以增强裁决科学性，增强气候变化争端案件透明度，以及明确气候变化事实举证倒置。黄世席[4]指出投资者利用仲裁作为迫使东道国妥协的工具，实践表明 ISDS 制度已经对国家管理公共利益政策和法治的主权构成挑战。黄世席提出应该对 ISDS 条款进行革新，确保东道国在解决投资争端中的优先地位，明确仲裁员的选拔和道德标准，同时规定在将来可行时设立上诉机制，增加仲裁程序的透明度和把环境、劳工和健康保护措施明确列为一般例外。王艳冰[5]认为现有的国际投资争端解决程序忽视气候变化问题，没有将东道国缓解气候变化措施列为可诉事项的例外，在仲裁员的选任上也未考虑相关人员在气候变化问题的专业程度。

在实体方面，学者们主要的修改意见集中在投资条约的公平公正待遇、最惠国待遇、征收条款、国民待遇以及气候变化例外上。王艳冰[6]认为国际投资条约

[2] 参见刘万啸：《气候变化背景下外国投资者与政府争端的解决——以我国双边投资协定为例》，载《政法论坛》2012 年第 6 期，第 96-101 页。

[3] 参见李坤海：《投资仲裁中协调气候变化投资与东道国气候变化保护冲突的困境与对策》，载《大连海事大学学报》2021 年第 6 期，第 69-74 页。

[4] 参见黄世席：《可持续发展视角下国际投资争端解决机制的革新》，载《当代法学》2016 年第 2 期，第 28-34 页。

[5] 参见王艳冰：《气候变化与国际投资法应对》，载《法治论坛》2011 年第 3 期，第 60 页。

[6] 参见王艳冰：《国际投资法实现气候变化正义之理论路径与实践原则》，载《学术界》2013 年第 186 期，第 95 页。

中国知网 https://www.cnki.net

应以“作为公道的气候变化正义”为导向来搭建法律框架，以“作为公道的气候变化正义”为导向来搭建法律框架，以“共同但有区别的原则”作为规则制定和实施的原则，从而确定东道国和投资者的权利义务。刘万啸[7]主张为应对气候变化要对不当投资保护条款进行修订。如果可能，要从国际投资条约中删除对投资者“设业权”条款。东道国签订投资条约时，要避免订入潜在限制东道国为公共利益采取的“稳定条款”。在具体的权利义务条款上，王艳冰[8]认为国民待遇和最惠国待遇没有为应对气候变化的措施留有余地，公平公正待遇对气候变化问题也避而不谈，征收条款没有明确为缓解气候变化采取的措施不构成间接征收。黄世席[9]指出国际投资协定规定的保护投资者及其投资的实体条款，如国名待遇、最惠国待遇和公平公正待遇，甚至征收条款，都有可能是投资者提起仲裁的根据，也是其用来质疑东道国治理气候变化政策的主要依据。现有国际投资协定规定环境条款的条约数量很多，但却只有极少部分条约直接规定了环境问题，而对气候变化问题做出直接规定的条约更是罕见。为应对气候变化问题，需要从根源上治理，包括对现有的国际投资条约进行修改或重新修订。黄世席提到了如下修改意见：一、在序言中进行明确规定环境价值或遵循可持续发展目标。二、实体标准上，明确投资者必须遵守东道国法律作为投资准入的条件，包括东道国制定的气候变化政策和承担的国际气候变化义务，同时细化“类似情形”标准，减少非歧视待遇条款适用的不确定性，并限制公平公正待遇适用的范围和条件。三、确认投资保护的例外条款，纳入环境保护和气候变化等因素。李俊然、赵俊娟[10]提出在国民待遇中“相似情形”的认定上，纳入气候变化因素的考量。即东道国为应对气候变化而采取的措施，使外国投资者与本国投资者存在差别待遇的，不应视为违反国民待遇原则。为应对气候变化，建议国际投资条约直接取消最惠国待遇条款。如果直接取消的难度较大的话，可以明确规定最惠国待遇不适用于为应对气候变化而采取的措施。而对于征收条款而言，应明确规定东道国为履行应对气候变化义务而采取的善意且合法的措施不构成间接征收。

我国国内学者主要是站在可持续发展角度研究国际投资条约的完善和改进方向，直接站在气候变化角度上的研究较少，但气候变化问题只是可持续发展问题的一个重要方面，二者不可等同。而且学者对投资条约的修改意见仍然较为模糊概括，不够具体。例如对于国民待遇或者公平公正待遇此类模糊性的条款上，学者提到要明确具体适用标准，减轻仲裁者的自由裁量，但在文章中却未写明该

[7] 参见刘万啸：《气候变化背景下国际投资规则的发展趋势及我国对策研究》，载《政法论丛》2014年第2期，第100页。

[8] 参见王艳冰：《气候变化与国际投资法应对》，载《法治论丛》2011年第3期，第58-59页。

[9] 参见黄世席：《全球气候变化治理与国际投资法的应对》，载《国际法研究》2017年第2期，第15-25页。

[10] 参见李俊然，赵俊娟：《国际投资协定与气候变化协定的冲突与协调——以国际投资协定的实体规则为视角》，载《河北法学》2019年第7期，第138-139页。

中国知网 https://www.cnki.net

如何对此类条款进行具体修改。这种过于宽泛的修改意见对以后投资条约的改革参考价值不大。因此，在提及到修改上，应进一步具体到如何修改，而非简单的方向指导。

2.国外研究现状

国外研究也同样集中在实体和程序两方面的修改。在具体改进措施上，国外学者提出的改进建议比国内明显走的更远，提出的具体措施突破了表层，深达具体条文。在程序上，Paula Henin, Jessica Howley, Amelia Keene, Nicola Pear[11]指出，在争议解决条款中规定 ISDS 条款只适用于气候变化友好型投资争议中。在仲裁的审理期限上，作者建议规定三年的审理期限，以督促仲裁庭能够及时审理投资争议，确保气候变化友好型投资者的合法利益得到及时维护。同时，还提出投资条约同时规定六个月的冷静期，及在仲裁前采取强制性调解措施。针对 ISDS 缺陷，作者认为应该提将联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）关于透明度规则运用到仲裁中，加强仲裁员的自身素质，指定环境法方面的专业人员当任仲裁员，并建立永久仲裁员专家库。为了保护弱小投资者仲裁权，仲裁条款还应该赋予仲裁庭一定的自由裁量权，在具体情形下东道国未同意时仍然可以针对有关诉求进行仲裁。Bradly J. Condon[12]认为投资条约会限制东道国采取气候变化措施的管理能力。该文以北美自由贸易协定（NAFTA）下成员国几个案子论述分析仲裁庭的裁决，论述了投资条约里备受争议的最低待遇、征收、以及非歧视待遇义务。并指出仲裁庭在裁决时应该考虑东道国的规制权，不应该让投资条约作为东道国采取保护气候变化措施的阻碍。Anatole Boute[13]也指出，在东道国面对气候变化采取政策规制时会与现有投资产生矛盾，投资者往往以东道国违反政策稳定性而被诉诸仲裁庭，威胁东道国的规制权，面对此种矛盾，作者指出应该要让投资者自身明白，政策稳定性并不意味着法律是丝毫不动的。在文章中作者提到了京都议定书应该作为仲裁庭在仲裁时应该考量的法律因素，在面对投资者以东道国违反投资协定为由提起仲裁时，仲裁庭除了投资协定外，还应考虑以京都议定书等此类的国际法律义务，综合考虑东道国是否有违约。

---

[11] See Henin, Paula & Jessica Howley et al., *Innovating International Investment Agreements: A Proposed Green Investment Protocol for Climate Change Mitigation and Adaptation*, 36 Journal of International Arbitration 37,43-49, (2019).

[12] See Condon Bradly J, *Climate Change and International Investment Agreements*, 14 Chinese Journal of International Law 305,318-337 (2015).

[13] See Boute Anatole, *The Potential Contribution of International Investment Protection Law to Combat Climate Change,* 27 Journal of Energy & Natural Resources Law 333,343-369(2009).

中国知网 https://www.cnki.net

在实体方面 Josephine Dooley，Canberra[14]提到了规制权，即东道国有权对自己国家公共事务进行管制并因此不构成对投资条约义务的违反。在国际投资条约中应该明确东道国的规制权，对于东道国采取的有关缓解气候变化的措施不能作为违反投资义务而被诉诸仲裁。投资者在进行投资活动时也必须要尊重东道国的规制权。Meredith Wilensky[15]以 TPP 为样分析了在该条约中是如何在东道国的规制权和保护投资之间寻求了平衡。在间接征收条款中，tpp 明确规定了征收例外情形，即东道国为国内公共利益为由采取有关措施不能构成征收，调高了征收门槛。同时 TPP 对公平公正待遇条款也进行了限制性使用，将会减少 FET 的使用。对于国民待遇也将对“同类情形”进行细化，将纳入公共卫生、环境等公共利益因素进行考虑。TPP 同时预留了自由空间空间以供成员国采取气候变化管制，比如纳入环境例外条款。这些措施都足够让东道国有权采取相应气候变化措施而免于被仲裁风险。该文以 TPP 为模版进行了分析，作者试图通过这类分析给未来投资条约的修改提供参考和借鉴，平衡现有投资条约利益失衡现状。Martin Dietrich Brauch 等人[16]提出，要对可持续投资和投资者在实体上采取特别的对待，从而挫伤非可持续投资的积极性。非歧视待遇只能运用在类似情形上，作者对于类似情形做了正向例举的方式，即投资是否对有利于保护气候变化、是否是可持续投资，对于可持续投资和非可持续投资主张采用不同的投资待遇标准。文中明确反对在投资条约中约定模糊不清的公平公正待遇以及最低待遇标准。

（四）研究方法

1.案例分析法

从国际仲裁实践出发，通过对与气候变化、环境保护等有关的投资争端案例的研读，研究现有国际投资条约在应对气候变化上的缺陷与不足。分析国际投资协定中间接征收条款、公平公正待遇条款对环境保护条款适用影响，从而使国际

[14] See Dooley Josephine & Canberra, *The Co-Existence of Mitigation and International Investment Law: A Practical Assessment of Climate Change Action Under Less“Green-Friendly” Investment Agreements,* 23 Journal of World Investment & Trade 849,864-881(2022).

[15] See Meredith Wilensky, *Reconciling International Investment Law and Climate Change Policy: Potential Liability for Climate Measures Under the Trans-Pacific Partnership,* 45 Environmental Law Reporter 10683,10683-10697 (2015).

[16] See Martin Dietrich Brauch et al., *Treaty on Sustainable Investment for Climate Change Mitigation and Adaptation: Aligning International Investment Law with the Urgent Need for Climate Change Action,* 36 Journal of International Arbitration 7 ,10-33(2019).

中国知网 https://www.cnki.net

投资条约未来在应对气候变化和投资者利益之间达到平衡与协调。

2.实证与规范分析相结合

对国际投资条约中影响东道国应对气候变化的条款进行实证研究，对其中可能妨碍减缓和适应气候变化的规定予以规范分析，以探求完善国际投资协定从而体现气候变化关切的路径和方法。

中国知网 https://www.cnki.net

一、气候变化对国际投资条约提出的挑战

气候变化越来越明显，其引起的严重后果已成为不争事实。针对气候变化，国际上从忽视、认识到重视，并制定了一系列有关的国际条约。在倡导可持续发展潮流下，国际投资这一偏向经济发展的天平也不得不开始向保护气候变化一方做出倾斜。国际投资条约也必须随之时代更替做出相应的更新换代，在经济发展和缓解气候变化之间做出平衡，方可适应时代发展。

（一）气候变化引起的次生灾害造成重大损失

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告（AR6）第二工作组的报告显示，海陆热浪、强降水、干旱和火险天气等极端气候变化和天气事件的频率和强度增加带来了广泛而普遍的影响[17]。过去五十年，气候变化灾害总数超过 11000 起，死亡人数超过 200 万人，经济损失高达 3.64 万亿美元[18]。关于气候变化带来的影响，发展落后的国家感受更为直接。受气候变化的影响，极端天气日益频繁，埃及粮食安全和水资源问题愈发突出，生物物种多样性也遭受了严重的破坏。埃及位于中东地带，大部分地区属于热带沙漠气候变化，埃及主要水资源来自尼罗河，而气候变化导致的干旱使尼罗河的水量极速减少。据估计，在整个 21 世纪，气候变化将使尼罗河流量的标准差增加约 50%，意味着发生洪水和干旱的可能性都增加了两倍[19]。近几年气候变化导致海平面上升的也对埃及尼罗河三角洲带来了威胁，尼罗河三角洲是埃及的重要粮食生产地，占埃及 60% 多的农耕地，其地势低洼。有研究显示，地中海海平面上升 1 米，将淹没四分之一以上的三角洲土地[20]。这对落后的埃及人民来说，将是不可承受的灾难。此外，因气候变化带来的极端天气，在过去的几年里已经给埃及人民造成了巨大的人员伤亡和经济损失。反观我国，近几年，因气候变化也遭受了巨大的人员和财产上

[17] IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,Cambridge: IPCC, 2022.

[18] WMO, *WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather,* Climate and Water Extremes (1970—2019),Geeva: WMO, 2021.

[19] Schaefer Sarah，*Climate Change: The Nile River*，Middle East Policy Council,June 21,2021,https: / /mepc.org /commentary /climate-change-nile-river,上网时间: 2023 年 10 月 17 日.

[20] Hereher Mohamed E.. *Vulnerability of the Nile Delta to Sea Level Rise: An Assessment Using Remote Sensing,Geomatics,* 1Natural Hazards and Risk 315(2010).

中国知网 https://www.cnki.net

的损失，根据我国官方数据统计[21]，我国 2023 年前三季度光因台风灾害就造成 807.8 万人次受灾，8 人死亡失踪，直接经济损失 324.8 亿元，福建、广东两省受灾相对较重。而且 2023 年 7 月底的“杜苏芮”台风为我国建国以来第二大超强台风，其破坏程度更是嗔目结舌。正是基于气候变化所引起的次生灾害给人类造成的巨大人员和财产损失直观的发生在我们现实生活，国际上对气候变化保护的呼声愈发高涨。

（二）国际投资条约与环境保护条约矛盾日益明显

据统计，1987-2021 年之间，有关环境的 ISDS 案件总计 175 起，与化学燃料有关的 ISDS 案件有至少 192 件，与可再生能源有关的案件至少有 80 件。值得注意的是，这些数据仅仅针对已公开的案例进行的统计，在实践中，仲裁庭根据案件性质和基于当事人的隐私问题，许多案件信息未予以公开，因此实际的真实案件数量会比统计的数量多。有关环境的 175 件案件中，除去三分之一悬而未决的案件，出结果的 118 件案件中，40%的判决有利于东道国。38%的判决有利于投资者，要求采取措施应对气候变化的东道国给予投资者赔偿。[22]与环境有关的投资争端数量不断增长，表明投资争端对国际和国内的环境法越来越敏感。目前国际投资条约与环境保护条约之间的频繁冲突表明环境法和投资法的关系正在演变。[23]条约冲突的根源在于条约的目的和宗旨不同，环境保护条约的目的和宗旨在于保护环境，侧重于公共利益。而投资条约侧重于投资保护，侧重于私人利益。而许多东道国是都是两类条约的缔约国，承担者两类的条约义务，即同时承担保护环境和保护投资的义务。这两类义务常使得东道国陷入两难之地，实施环境保护措施违反投资保护义务，反之实施投资保护措施却违反环境保护义务。

（三）气候变化制约着国际投资条约的适用

最近不断出现因东道国为应对气候变化而采取的措施被仲裁的案例导致各国掀起了修改国际投资条约的热潮，不合时宜的国际投资条约也被不断修改。气候变化促使缔约国思量现行签订的国际投资条约，使国际投资条约不像先前被投

[21] 中华中华人民共和国应急管理部：《应急管理部发布 2023 年前三季度全国自然灾害情况》，中华人民共和国应急管理部网站，https://www.mem.gov.cn/xw/yjglbgzdt/202310/t20231008_465002.shtml，访问日期：2023 年 10 月 10 日。

[22] See UNCTAD, *International Investment in Climate Change Mitigation and AdaptationTrends and Policy Developments*, 2022, p.23–24.

[23] 刘万啸：《全球治理视野下环境保护与国际投资体制的冲突与协调》，载《齐鲁学刊》2017 年第 4 期，第 98 页。

中国知网 https://www.cnki.net

资者肆意使用来维护自身的不当利益。虽在仲裁实践中，较大多数的仲裁庭都是偏向保护投资者利益而忽视东道国的合法利益。但也不乏有仲裁庭本着公平公正原则，立足于东道国的公共目角度做出裁判，在 Methanex Corporation v. United States of America 案[24]，Methanex 公司是加拿大投资者在美国设立的一家全球最大的甲醇生产商和经销商，甲醇是甲基叔丁基醚的关键成分，可用于增加氧气含量并在无铅汽油中作为辛烷值增强剂。1999 年加利福尼亚发布行政命令：“总的来说，在加利福尼亚州的汽油中使用甲基叔丁基醚会对环境造成重大风险。”故加州能源委员会与加州空气资源委员会决定尽早从汽油中去除甲基叔丁基醚。随后加州福利亚法规在第（a）条第（1）款中规定：“从 2002 年 12 月 31 日开始，任何人不得出售、要约出售、供应或要约供应使用甲基叔丁基醚生产的加利福尼亚汽油”。修正后的加利福利亚法规则明确规定禁止在加州使用甲醇作为含氧化物。1999 年 12 月 3 日，Methanex 公司向国际投资争端解决中心（ICSID 中心）提交仲裁，以美国当局违反 NAFTA 第 1102 条、第 1105 条和第 1110 条为由要求赔偿 9.7 亿美元。申请人提出在加州禁止甲基叔丁基醚之前炼油厂都需要从申请人处购买甲醇用于制造甲基叔丁基醚，自法规禁止之后，炼油厂转向使用乙醇，导致申请人的销售量大大折扣，加州该行为已经违反了 NAFTA 中国民待遇、最低待遇标准并且已经构成了征收，因此必须予以赔偿。美国在仲裁庭中提出，甲醇与乙醇之间没有二元选择，不构成类似情形，做出禁止甲基叔丁基醚的决定完全是基于考虑环境和气候变化等因素的考虑，并非是歧视申请人，并且其措施不具有剥夺性因此不成立征收。最后仲裁庭认为美国不违反上述规定未支持申请人的索赔。仲裁庭认为，根据一般国际法，针对公共目的的法规是根据正当程序制定的，且是非歧视性的。对于这类法规除非东道国政府对外国投资者做出了具体承诺，否则不应被视为具有掠夺性和可补偿性。在此案中，仲裁庭考量了东道国做出法规的目的，保护了东道国基于公共目的合法规制权。在气候变化影响人类生活日益严重下，并且有关气候变化保护的国际条约的缔结和缔约国数量的增加，仲裁庭在做出裁决时不可避免的会将政府合法规制权纳入考量范畴，单一的唯国际投资条约论将退出舞台，越来越多的因素将在不断进入仲裁庭视野。投资者再也不能仅凭国际投资条约的规定和自身的实际损害结果就让东道国的为公共目的规制行为变成侵权行为，夹在东道国和投资者之间的失衡的天平将得到重新的平衡。国际投资条约在阻碍东道国实施保护气候变化行为的同时，气候变化改变了国际投资条约的适用背景，也对以往落后的老一代的国际投资条约起着制约作用。

[24] Methanex Corporation v. United States of America，ICSID，judgment of August 3, 2005.

中国知网 https://www.cnki.net

二、现有国际投资条约应对气候变化问题不足的诱因

国际投资条约在应对气候变化问题上的缺失有不可忽视的历史因素。从上世纪 50 年代发展起来的双边投资条约（BIT），起初主要是发达国家在资本输出时用来保护本国投资者的工具。[25]投资条约这一工具属性，注定其在东道国公共利益和投资者私人利益的天平上是不平衡的，注定其要侧重保护外国投资者的私人利益。在国际投资领域，新自由主义一直占据主导地位，新自由主义倡导政府管制最小化，倡导经济的自由发展。加上当时气候变化并不明显，国际社会保护气候变化观念薄弱，自然导致当时的投资条约忽视气候变化问题，偏袒投资保护而限定政府的规制权。经济发展曾是国际关系发展的主旋律，气候变化变暖在工业革命时期已经开始，但在 20 世纪 90 年代才成为全球性重要议题，其中 1992 年的“环境与发展会议”被认为是环境史上发展的里程碑。[26]从这之后，国际社会对气候变化问题愈发重视，伴随而来的气候变化问题与投资保护问题二者的矛盾开始激增，频繁发生的投资争端引起了各缔约国对初代投资条约的重新审视。

（一）国际投资条约对气候变化问题含糊不清

1. 国际投资条约序言条款应对气候变化的缺失

现有投资条约在序言上大多规定促进投资，在国际投资中东道国保护投资的义务和投资者在投资中的投资权利。近几年，随着可持续发展观念的推进，投资条约序言中开始纳入可持续发展因素，如环境保护、劳工保护和公共健康等，但气候变化因素却鲜有提及。《维也纳条约法公约》（下称 VCLT）第 31 条规定条约解释因素包括序言和目标与宗旨，该条约解释规则经各国多年反复适用已成为习惯国际法。作为条约的组成部分，序言中规定的基本原则、缔约目的和宗旨，在争端解决中是裁决机构和当事人解释条款含义的重要依据，对条约解释具有一定的约束力。[27]尽管在学界和实务实践中对于序言的法律法律效力存在着争议，部分学者认为序言仅具有解释性价值的作用，并不会对缔约主体的具体的权利和义务产生任何影响。由于国际条约用词模糊、高度概括性等特点，往往在具体适

[25] 蒋小红：《试论国际投资法的新发展——以国际投资条约如何促进可持续发展为视角》，载《河北法学》2019 年第 3 期，第 45 页。

[26] 李坤海：《投资仲裁中协调气候变化投资与东道国气候变化保护冲突的困境与对策》，载《大连海事大学学报（社会科学版）》2021 年第 6 期，第 71 页。

[27] 冯寿波：《论条约序言的法律效力——兼论 TRIPS 序言与〈WTO 协定〉及其涵盖协定之序言间的位阶关系》，载《政治与法律》2013 年第 8 期，第 93 页。

中国知网 https://www.cnki.net

用中会有着分歧。而序言记录了缔约背景、规定了条约的目的和宗旨，奠定了条约的基调，是一个条约精神的高度概括。因此在实践中，当事人都不可避免的引用条约序言作为自己行为合法性的佐证，同时争议解决机构在争议解决实践中通过引用序言来论证自己的裁判理由的合理性。在“sanum v. 老挝案”中，sanum 是一家依据澳门特别行政区法成立的一家公司，2007 年 sanum 公司开始在老挝投资赌博行业。2013 年，sanum 公司在新加坡提起仲裁，其认为老挝政府通过不公平、歧视性的税收征收了他们的投资收益。因此以老挝政府违反中国-老挝 BIT 公平公正待遇、最惠国待遇、征收条款等为由向主张赔偿。老挝政府对于仲裁庭的管辖提出了异议，认为仲裁庭无权管辖该案件。在 2013 年 12 月 13 日，仲裁庭做出管辖权裁决，认定仲裁庭享有管辖权。裁决做出后，老挝政府不服并向新加坡高等法院提交申请，后新加坡高等法院于 2015 年 1 月 20 日做出判决，撤销仲裁庭的裁决，认定仲裁庭无管辖权。同年 sanum 公司提起上诉，最后新加坡上诉法院做出判决，推翻了高等法院判决，认为仲裁庭享有管辖权，老挝政府败诉。该案的争议焦点之一是中国-老挝 BIT 第 8（3）的适用问题，对该条的解释将直接影响仲裁庭对案件的管辖权。上诉法院考虑到中国-老挝 BIT 序言中包含鼓励投资和促进相互经济合作的规定，最终主要从序言中的条约目的和宗旨出发，裁定仲裁庭对是否存在征收问题也享有管辖权，最后 sanum 公司才得以胜诉。国际投资条约因自身的局限、国际关系的复杂、模糊、成员之间利益的博弈等各种原因，使序言对于投资条约解释问题来说并非可有可无，也并不是学者主张的不具有法律效力而是变得异常重要和敏感，其在实践中对正文具体的含义的解释起着一个参考、补充、限定的作用。在条约具体含义不明确的内容，序言或许会成为仲裁庭或当事人裁决或者胜诉与否的关键。

以我国为例，我国签订的投资协定中，早期签订的投资协定，序言多是无任何有关气候变化问题的规定，主要体现的是促进投资为目标。我国与俄罗斯 2006 年 11 月 9 日签订的《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于促进和相互保护投资协定》序言就未提到以应对气候变化为目标或宗旨，短短几句序言里，不断重复着为投资创造机会，保护和促进投资，加强两国合作。我国与荷兰于 2001 年 11 月 26 日签订的《中华人民共和国政府和荷兰王国政府关于鼓励和相互保护投资协定》序言“.....扩展两国经济关系，特别是缔约国一方投资者在缔约另一方领土内进行投资方面。认识到同意给予上述投资的待遇有助于促进资本和技术的流动以及增进缔约双方的经济发展.....”也未规定任何针对气候变化问题的措施，而是以单一促进投资发展作为条约的目的和宗旨。就连近年签订的双边投资协定，仍有在序言里只规定促进投资单一目标，如中国与土耳其签订的《中华人民共和国政府和土耳其共和国政府关于相互促进和保护投资协定》序言就只规定鼓励和保护投资，未涉及其他目标。近些年签订的双边投资协定序言除了规

中国知网 https://www.cnki.net

定促进投资，增加了其他的目标和宗旨，但遗憾的是，气候变化问题并未直接在序言中体现，而只是包含在可持续发展目标中。我国于 2012 年 9 月 9 日与加拿大签订的《中华人民共和国与加拿大政府关于促进和相互保护投资的协定》，序言中明确写明“进一步认识到需要依据可持续发展的原则促进投资”。在 2022 年 1 月 1 日生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），作为我国近年以来签订的最大的区域多边投资协定，RCEP 比较具有代表性，表明着我国近年来对待投资协定的态度和发展趋势，在协定序言“重申每一缔约方为实现合法的公共福利目标而进行监管的权利；认识到可持续发展的三大支柱是相互依存、相互促进的，以及经济伙伴关系能够在促进可持续发展方面发挥重要作用；”映射出我国对可持续发展的态度，不似从前只侧重经济发展，同时重申缔约国为公共福利目标监管权利也是对东道国的保护环境措施被仲裁的回应。较之前的投资条约，RCEP 序言中明确缔约国的监管权、可持续发展目标，但同样序言未明确提及气候变化。我国投资条约的发展是国际投资条约发展的缩影，国际投资条约大多是这种改革趋势，从一开始的的序言中单一规定促进经济发展，促进国际投资目标，到纳入可持续发展。总体上来说，现在条约规定可持续发展目标的做法越来越普遍，但是却仍未直接在序言中写明应对气候变化这一具体目标，这无疑对之后的具体条约解释仍然埋下了隐患。

2. 东道国实体义务条款不完善

国际投资条约为了促进投资发展，在条约文本采取原则性条款规定东道国保护投资者义务，为尽可能的保护投资者利益，扩大保护范围，加上立法上技术的限制，该类保护义务以原则性条款呈现，如国民待遇、最惠国待遇、公平公正待遇、征收条款等。该类原则性条款尽可能的大范围的保护了投资者利益，也尽可能的大范围的约束了缔约国的义务，保证投资者在外国投资时能够利益保护最大化。该类投资义务在早期法制不健全的时候的确发挥了重要作用，防止投资者因为东道国法制落后而遭受损失，最大限度的保护投资者使投资者积极投资，促进了全球的资本的流动。但正如前所述，随着气候变化的变化，因为这些东道国义务条款因为没有明确的适用范围，被投资者滥用，许多东道国的气候变化规制措施被投资者仲裁到法院而面临着赔偿。

（1）国民待遇

国民待遇主要是防止东道国差别对待外国投资和本国国内投资，对外国投资设定更高标准，间接削弱其竞争力，从而非法侵害外国投资者的合法利益。国民待遇原则无视投资领域和投资来源，一概要求只要是外国投资者，那么在“同等条件下”其所获的的投资待遇就应该与东道国国民所享有的待遇应该一致，否则东道国就违反了国民待遇原则，就得承担相应的违约责任。国民待遇原则的形式

中国知网 https://www.cnki.net

公平已被投资者用来质疑东道国应对气候变化的措施。例如在“Claton-Bilcon v. Canada 案”[28]中，Claton-Bilcon 想在加拿大海岸边扩大自己的采石场和海运码头项目，根据东道国法律规定，其必须或得地方和联邦许可。后东道国环境影响评估小组经评估后为保护环境建议不应该继续该项目，因此联邦和地方都裁定不予以颁发许可证。后 Claton-Bilcon 以加拿大违反了 NAFTA 中国民待遇原则提起仲裁，要求予以赔偿，最后得到了仲裁庭的支持。以往的国民待遇只适用于投资准入后，但在近几年，美国、加拿大等发达国家将国民待遇的范围扩大到投资准入前，即要求在投资准入前也要对外国投资者适用国民待遇。[29]这种肆意扩大国民待遇适用范围的行为将容易进一步激化东道国投资者保护义务与应对气候变化义务之间的矛盾。国民待遇与气候变化保护之间的矛盾主要是由技术发展和国与国之间的差距所引起的。

《联合国气候变化框架公约》确定了在因自身实力、国情不同发达国家和发展中国家承担“共同但有区别责任原则”以应对气候变化的义务。因此在国际投资中，发达国家的投资者在发展中国家投资时，其应该承担比发展中国家的国内投资者更高的应对气候变化的义务，尤其是对于碳排放方面，因发达国家投资者经济力量雄厚，技术先进，根据“共同但有区别责任原则”其应该尽可能的减少碳排放量。但在实践中，发达国家投资者为了减少碳排放成本，往往引用国际投资条约中的国民待遇原则，意图享受与发展中国家投资者一样的低标准，从而减少自身成本。而在现有的国际投资条约中，对于国民待遇并未做出任何气候变化因素的考量，未考虑发达国家和发展中国家国家能力的差别，要求应对气候变化能力弱的发展中国家给予能力强的发达国家投资者不低于本国国民的待遇，这种做法默认允许发达国家的投资者在发展中国家投资时可采取低于投资母国的标准进行碳排放。在同一行业领域，因技术发展不同，不同的投资可能对气候变化的友好程度也不同。好比现在汽车行业，新能源汽车和传统类使用石油的汽车比，新能源汽车无疑对环境更为友好。为了应对气候变化，引导技术革命，促进气候变化友好型投资的发展，东道国会刻意的对气候变化友好型投资和非气候变化友好型投资进行“区别对待”，制定不同的税收等优惠政策，意图促进环境保护。因此，虽然二者都是汽车行业，新能源汽车类投资就会比传统类的汽车投资享受更优惠的政策，但国民待遇却未将是否气候变化友好纳入适用范围，有关投资者仍然可以通过投资条约中的国民待遇原则使非气候变化友好型投资与气候变化

[28] William Ralph Clayton，William Richard Clayton，Douglas Clayton，Daniel Clayton and Bilcon of Delaware Inc. v. Government of Canada，UNCITRAL，PCA Case No. 2009 – 04，Award on Jurisdiction and Liability,17 March 2015,para. 731.

[29] 李俊然、赵俊娟，《国际投资协定与气候变化协定的冲突与协调——以国际投资协定的实体规则为视角》，载《河北法学》2019 年第 7 期，第 132 页。

中国知网 https://www.cnki.net

友好型投资享受东道国的同等福利待遇。而东道国在巨大的赔偿的压力前，也往往对于类似情况不得不对不同类型投资一视同仁，赋予同等国民待遇。在以上两种情形下，发达国家与发展中国家国民和气候变化友好型与非气候变化友好型投资都依据国民待遇原则享受到了同等待遇，在形式上国民待遇原则上做到了公平，但却非实质公平，而是以牺牲东道国气候变化利益换来的形式公平。

（2）最惠国待遇

国际投资法中最惠国待遇是指东道国给予外国投资者的待遇不低于将要给或者已经给予第三国投资者的待遇。国民待遇规定的外国投资者待遇与本国投资者待遇一样，防止东道国歧视外国投资者而给予本国投资者更优惠的政策，最惠国待遇规定的是在外国投资者中保证所有外国投资者所受待遇一致，防止东道国歧视此外国投资者而给予彼外国投资者更优惠的政策。在国际投资法律关系中，最惠国待遇具有“多边化”效应，一旦一国给予另一国投资者以更高的待遇，那么与该一国订有最惠国待遇条款的其他所有第三方国家投资者均将有权获得这样的更高待遇。[30]最惠国待遇是国际投资条约普遍采纳的一个规则，该规则像铁链一般，将各个零散规定不一的国际投资条约链接起来，使各个标准不一的国际投资条约最后达到同样标准。这种看似将所有条约标准统一化，使各外国投资者享受同等待遇的公平做法实则引发了一系列矛盾。在仲裁实践中，仲裁庭肆意解释最惠国待遇，使最惠国待遇不仅阻碍了国际投资条约的更新换代，更加剧了现有国际投资条约的不平衡性和碎片化。[31]一方面国际投资条约中对最惠国待遇条款未明确规定具体适用范围，另一方面现有国际投资仲裁机构的自由裁量权过大，导致在实践中最惠国待遇条款的适用问题十分混乱。

是否适用第三方条约中有关投资者与国家间争端解决程序及第三方条约中实体义务是近年来最惠国待遇饱受争议的问题，而仲裁结果的不一也加剧了该争议。根据最惠国待遇，投资者是否可以任意引用基础条约不存在的实体义务。在“MTD 诉智利案”[32]中，MTD 是马来西亚一家公司，拟寻求在智利圣地亚哥附近开发一个住宅和商业综合体。后 MTD 公司找到一处合适土地并拟在该土地上修建商业楼，但该土地为农业用地。根据智利法律，农业土地在被政府相关部门重新划分为商业用地前不得以商业用途进行建造房屋。在 1998 年 4 月份，在投资了近 1700 万美元后，智利有关政府机构表示基于当地的城市发展和环境政策考虑，上述土地性质不能做出改变，经 MTD 公司多次与当地政府沟通无果后，MTD 公司及 MTD 智利公司依据 1992 年《智利-马来西亚 BIT》向 ICSID 提起仲

[30] 徐崇利：《从实体到程序：最惠国待遇适用范围之争》，载《法商研究》2007 年第 2 期，第 41 页。

[31] 王彦志：《从程序到实体：国际投资协定最惠国待遇适用范围的新争议》，载《清华法学》2020 年第 5 期，第 182 页。

[32] MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile,ICSID Case No. ARB/01/7.

中国知网 https://www.cnki.net

裁。在仲裁庭中，MTD 公司基于基础条约《智利-马来西亚 BIT》中最惠国待遇条款引用了第三方条约《智利-丹麦 BIT》第 3 条第（1）款保护伞条款和《智利-克罗地亚 BIT》第 3 条第（2）款规定的“东道国应在批准投资后给予相应许可”作为诉求基础，并以智利方违反上述实体义务为由要求赔偿，最后仲裁庭支持了 MTD 公司的主张，要求智利予以赔偿 MTD 公司 5871322.42 美元。在该案中，仲裁庭支持了投资者基于基础条款中的最惠国待遇条款去引用基础条约不存在但规定于其他第三方条约中的实体义务条款，并且认为基于基础条约中最惠国待遇条款东道国仍然要受其他第三方条约义务的约束从而给予外国投资者相关的待遇优惠，而不能因为基础条约中未予以规定就拒绝给予相关优惠待遇。而在“Teinver 诉阿根廷案”[33]中，仲裁庭对最惠国待遇条款的适用范围做了更严的解释，其认为对于最惠国待遇条款的适用，投资者只能据其引用第三方条约来改进基础条约已有的实体义务，而不能纳入基础条约中原本没有的新的实体义务。

在“Siemens A.G. v. The Argentine Republic 案”[34]中，申请人西门子公司以投标的方式为阿根廷政府提供移民管制、个人身份查验和选举信息系统等数据处理所需的设备及设备间相互通信、启动、技术支持和维护服务等，同时还负责阿根廷国民身份证的制备、印制和递送等服务。为了参与投标，西门子特此通过并入的一家公司 SNI 公司在阿根廷国内创立了 SITS 公司用于在阿根廷提供服务。最后 SITS 公司成功中标，与阿根廷政府签署相关合同并为阿根廷国民提供印制身份证服务。国民身份证原定于 1998 年 8 月开始生产，但因阿根廷选举要求 SITS 公司延迟生产。选举结束后新政府上台后 SITS 被告知运行移民管制子系统需要政府授权，因无政府授权使得 SITS 公司无法运行该子系统，导致其业务无法正常开展。同年新国民身份出现了技术错误，且阿根廷政府禁止 SITS 公司对该问做出修改，SITS 公司不得不暂停身份证的生产。这两次暂停都发生在阿根廷政府寻求对国民身份证价格做出重新协商定价的背景下，为此在 2000 年 3 月，政府建立相关委员会，SITS 公司与委员会就其提出的一项建议达成合意。SITS 公司后于 2000 年 12 月会见阿根廷总统，总统表示会发布法令批准合同重新协商建议的谈判条款，但之后并未如期得到相关法令批准。在 2001 年 5 月 SITS 公司从阿根廷政府收到了不同于合同建议的新建议草案，并且被告知新建议不可协商。同月阿根廷政府根据《经济金融紧急法》终止了与 SITS 签订的合同，SITS 公司不服，提起行政上述，但后被驳回。最后 SITS 依据《阿根廷-德国 BIT》提起仲裁，认为阿根廷上述行为已构成非法征收，要求予以赔偿。在仲裁过程中，阿根廷政府对仲裁庭的管辖权提出异议，其认为根据《阿根廷-德国 BIT》有关争议

[33]Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. Argentine Republic,ICSID Case No. ARB/09/1.

[34] Siemens A.G. v. Argentine Republic,ICSID Case No. ARB/02/8.

中国知网 https://www.cnki.net

解决条款的规定，SITS 公司无权在该时间提起仲裁，此时的仲裁庭无权做出管辖。对于该异议，SITS 公司认为其根据《阿根廷-德国 BIT》最惠国待遇条款的规定，其有权援引阿根廷与其他国家签订的投资条约中有关争议解决条款相关的规定，其认为争议解决活动也是投资相关的活动，也应在最惠国待遇条款的适用范围内。最后仲裁庭认为根据《维也纳条约法公约》对《阿根廷-德国 BIT》进行条约解释，最后认为 BIT 条款中的最惠国待遇条款应该也适用与争端解决条款，据此认定自身具有管辖权，最后裁决阿根廷政府需承担相关赔偿责任。而在“Plama v.Bulgara 案”[35]中，仲裁庭认为将最惠国待遇条款适用于投资争端解决程序事项中会造成投资者挑选条约，反而更不利于国际投资条约的协调，因此其拒绝将最国际投资条约中的争端解决程序纳入到最惠国待遇条款中的适用范围。

在气候变化问题严峻的今天，难免有东道国为了应对气候变化，在对外签订相关投资协议时会刻意的引导外国投资者进行气候变化友好型投资，并对外国投资者气候变化友好型投资给予更优惠的税收政策或其他福利待遇。但现有的最惠国待遇条款并未纳入任何气候变化因素考虑，未能明确最惠国待遇的适用范围。这使非气候变化友好型投资者易利用最惠国待遇条款的漏洞，从而适用东道国与其他第三国投资条约中的实体权利，搭乘气候变化友好型投资的优惠政策的待遇，最终降低东道国采取措施应对气候变化的积极性。

（3）公平公正待遇

投资条约一般都规定公平公正待遇条款，公平公正待遇条款被认为是国际投资条约中的超级帝王条款。民法中的诚实信用原则一般只是在具体规则中没有规定或者存有争议的情况下得以补充或辅助适用，而公平公正待遇条款一般则是首先直接独立适用[36]。公平公正待遇条款自诞生之日起就是一个一个抽象、宽泛、模糊的条款，公平和公正两个词语就注定该条款本就该是模糊宽泛缺乏具体适用标准的，因为公平公正两词本就会因解释不同而导致适用结果不同。但该条款因其在条约中广泛的规定，又是属于投资者可以直接引用的实体条款且欠缺具体的适用标准，加上在公平公正待遇条款对气候变化问题避而不谈。RCEP 第十章第五条投资待遇规定了公平公正待遇条款“每一缔约方应当依照习惯国际法外国人最低待遇标准给予涵盖投资公平公正待遇以及充分保护和安全。”并进一步规定到“公平公正待遇要求每一缔约方不得在任何司法程序或行政程序中拒绝司法；充分保护和安全要求每一缔约方采取合理的必要措施确保涵盖投资的有形保护与安全；公平公正待遇和充分保护和安全的概念不要求给予涵盖投资在习惯国际法关于外国人最低待遇标准之外或超出该标准的待遇，也不创造额外的实质性权

[35] Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria ,ICSID Case No. ARB/03/24.

[36] 王彦志：《国际投资法上公平与公正待遇条款改革的列举式清单进路》，载《当代法学》2015 年第 6 期，第 148 页。

中国知网 https://www.cnki.net

利。”作为新近签订的投资条约，RCEP 较之前我国与法兰西共和国签订的《中华人民共和国政府和法兰西共和国政府关于相互促进和保护投资的协定》（以下简称“《中国-法兰西 BIT》”）第三条“任一缔约方应当根据普遍接受的国际法原则给予缔约另一方的投资者在其境内或海域内所作的投资公平和公正待遇”做出了进一步适用范围的解释和说明，但遗憾的是，无论是最近签订的 RECP 还是 2007 年签订的《中国-法兰西 BIT》，在公平公正待遇规定上，其适用范围还是过于宽泛。如此一来，东道国为应对气候变化而采取措施，比如禁止使用某种物质，禁止生产者生产某种产品，或者为了应对气候变化出台或修改相应国家政策法规，从而与外国投资者的投资时的期望有所冲突，或相关措施直接影响投资者的合法利益，都有可能被投资者提起仲裁要求予以赔偿。从近年的相关案例来看，对公平公正待遇，国际投资仲裁庭倾向于对习惯国际法上的最低待遇标准做出扩大解释。一些仲裁庭认为，现代国际习惯法上的最低待遇标准已经扩展到涵盖透明度要求和不违背投资者的合理预期等内容。[37]在 2016 年 Crystallex 案[38]中，申请人 Crystallex International Corporation（以下简称“Crystallex 公司）是一家加拿大的公司，其在 2002 年与委内瑞拉的一家矿业公司签订了采矿作业合同，根据合同规定，Crystallex 获得了在委内瑞拉 Las Cristinas 矿区开矿的权利签订合同后，申请人根据委内瑞拉法律规定获得了相关采矿许可。直到 2008 年，委内瑞拉给予本国 Las Critinas 矿区环境的考虑，拒绝给予 Crystallex 公司颁发采矿许可。申请人以委内瑞拉违反加拿大与和委内瑞拉于 1996 年签订的双方投资协定的第 II（2）条公平公正待遇条款为由，提起仲裁，要求委内瑞拉对申请人予以赔偿。在庭审中，委内瑞拉提出，之所以拒绝再度向申请人颁发开矿权许可，是基于保护当地环境考虑，该行为并非是任意果断，而是东道国行使政府公共管制权的体现，并且一再强调各国有权基于对本国环境的保护管理工业活动。但很遗憾，仲裁庭并未采纳被申请人委内瑞拉的上述抗辩理由，而是认为委内瑞拉损害了 Crystallex 公司依据其承诺做出了合理期待，因此委内瑞拉违反了投资条约中约定的公平公正待遇条款，因此需对申请人进行赔偿。仲裁庭的肆意解释并非“空口无凭”，独立的、未做任何限制的公平公正待遇给仲裁庭的扩张解释提供了充分“借口”[39]。公平公正待遇条款在国际投资条约中未明确应对气候变化的目的是导致仲裁庭无视东道国应对气候变化措施正当性的直接原因。实践中对公平公正待遇的解释往往涉及最低待遇标准，但二者之间的关系一直处于模糊状态，在

[37] 李俊然，赵俊娟：《国际投资协定与气候变化协定的冲突与协调——以国际投资协定的实体规则为视角》，载《河北法学》2019 年第 7 期，第 133 页。

[38] Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela ,ICSID Case No. ARB(AF)/11/2.

[39] 闫旭：《论公平公正待遇与最低待遇标准的关系——兼评 RCEP 投资待遇规则》，载《西部法学评论》2022 年第 1 期，第 129 页。

中国知网 https://www.cnki.net

解释公正公正待遇上是否要参照最低待遇标准也始终是实务界和理论界的困扰。[40]仲裁庭的自由裁量权是在投资条约没有明确规定的前提下，其依据相关的条约解释对国际投资条约的具体规定适用做出解释，其做出解释还是得以文本为基础，如公平公正待遇明确约定尊重东道国应对气候变化措施，明确其适用范围，理清公平公正待遇和最低待遇标准的关系，那么仲裁庭将无权背离条约的文本规定做出任意解释。

（4）征收条款

国际投资协定一般都规定了征收条款。但目前直接征收已很少采用，更多是间接征收。间接征收是指东道国政府在未从法律上取得外国投资者财产权的情况下，采取阻碍或影响外国投资者对其资产行使有效控制权、使用权或处分权的行为。[41]例如，在东道国为应对国内气候变化，对煤炭、石油等非清洁能源产业征收更多税，该措施将给外国非清洁能源产业的投资者的利益带来直接损失，投资产业的所有权尚未发生变化，但是对其投资利益产生了实质性的影响，投资者仍然可以以东道国有关措施构成间接征收而提起仲裁。近几年国际投资仲裁庭受理的案件，越来越多案件的投资者是以东道国采取环境保护措施构成间接征收为由提起的。间接征收条款已经成为各国政府在国际投资领域实施应对气候变化措施的现实难题，其极大的阻碍了东道国实施应对气候变化措施。近几年，投资条约关于征收条款开始关注到环境保护问题，并将善意、非歧视且合比例的东道国规制措施排除在征收之外。如《美国 2012 年双边投资条约范本》附件二规定“除非在极少数情况下，缔约方为保护公共卫生、安全和环境等合法公共福利目标而设计和实施的非歧视性监管行为不构成间接征收。”我国与乌兹别克斯坦于 2011 年 4 月 19 日签订的《中华人民共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府关于促进和保护投资的协定》第六条关于间接征收的例外规定“除非在例外情形下，例如所采取的措施严重超过维护相应正当公共福利的必要时，缔约一方采取的旨在保护公共健康、安全及环境等在内的正当公共福利的非歧视的管制措施，不构成间接征收。”上述征收条款将东道国为实施环境保护的行为排除在间接征收外，给东道国为公共利益实施管制措施留下了一定空间，也为仲裁庭区分间接征收和东道国的合理规制权提供了法律依据。但是，上述条约规定的环境保护范围十分宽泛，没有明确例举出气候变化这一特殊的环境问题。气候变化问题包含在环境保护这一大类中，但其又有自身的独特性。应对气候变化遵守的基本原则是共同但有区别责任原则，与一般环境保护措施不同的是，应对气候变化的措施不仅有高

[40] 闫旭：《论公平公正待遇与最低待遇标准的关系——兼评 RCEP 投资待遇规则》，载《西部法学评论》2022 年第 1 期，第 121 页。

[41] 张光：《论东道国的环境措施与间接征收——基于若干国际投资仲裁案例的分析》，载《法学论坛》2016 年第 4 期，第 61 页。

中国知网 https://www.cnki.net

碳和低碳之分，还有发达国家和发展中国家之别。[42]仔细推敲前述条约规定，只有在东道国实施的环境保护措施属于非歧视时方能认定为间接征收的例外情形，而应对气候变化要求发达国家与发展中国家承担不同程度的责任，本就不属于形式上的公平而与条约规定的非歧视相冲突，这就容易使东道国为应对气候变化采取的监管措施被认定存在歧视，从而面临被认定为间接征收。但近年签订的国际投资协定中存在大量这样的条款，这对发展中国家应对气候变化而言及其不利。[43]

现在仲裁庭认定东道国行为是否构成间接征收主要有三种做法。第一是只考虑东道国管制行为的效果，不考虑其行为动机，认为主要东道国的行为对投资者的的财产起到了实质损害就构成间接征收，即行为效果说。在“Metalclad Corporation v. the United Mexican States 案”[44]中，Metalclad 公司收购墨西哥工业固废技术股份有限公司拟从事废物填埋活动。在完成收购后，其建造填埋场所在地颁布饿一项关于保护珍稀仙人掌的生态法令，将该地区划分为自然保护区，并永久排除了填埋场在该地的运营。后 Metalclad 公司以墨西哥国家违反 NAFTA1110 征收等条款提起仲裁，要求予以赔偿。仲裁庭认为无需决定或考虑墨西哥当地政府出台生态法令的目的或者动因，因为该生态法令的实施本身就构成了间接征收，影响了投资者的实质投资利益，因此墨西哥需要承担赔偿责任。第二种方法是比例原则，即衡量东道国利益与投资者损失之间是否存在一种合理的比例关系。在“Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. The United Mexican States 案”[45]中，Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A.公司（以下简称“麦德公司”）是一家在西班牙注册成立的公司，在 1996 年收购了墨西哥一处危险废物填埋场及其相关资产。收购同年，墨西哥国家生态研究所（以下简称“生态研究所”）向麦德公司颁发了经营填埋场所需为期一年的许可证，此前该填埋场的许可证为无期限，但生态研究所给麦德公司的许可证需每年申请续期。许可证一年到期后，得到了正常续期，但在第二次到期麦德公司再申请续期时，生态研究所拒绝予以续期，并告知麦德公司关闭相关设施。理由是填埋场贮存废物量超出许可证授权限制，填埋场违规接受液体和生物传染废物和麦德公司不信守承诺将填埋场迁移至远离市中心的地区。麦德公司以墨西哥该行为构成间接征收为由提起仲裁，要求予以赔偿。墨西哥指出该填埋场仅被允许接收农用化学品或杀虫剂或

[42] 李俊然、赵俊娟：《国际投资协定与气候变化协定的冲突与协调——以国际投资协定的实体规则为视角》，载《河北法学》2019 年第 7 期，第 134 页。

[43] 王艳冰：《气候变化与国际投资法应对》，载《法治论坛》2011 年第 3 期，第 60 页。

[44]Metalclad Corporation v. United Mexican States ,ICSID Case No. ARB(AF)/97/1.

[45] Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. United Mexican States ,ICSID Case No. ARB(AF)/00/2.

中国知网 https://www.cnki.net

受此类物质污染的容器和材料产生的废物，但该填埋场却接受了液体和生物感染性废物，已经违反了相关规定，且其未经授权违规存储了危险废物。同时民众对该填埋场的意见越来越大，因此为了保护环境和应对气候变化、公共卫生等原因拒绝向其再颁发许可证，并且要求其关闭设施。同时墨西哥还指出该决议涉及到环境保护、公共卫生等事项是根据国家规制权实施的管制性措施，属于国家权力不应该被认定为征收。仲裁庭认为援引比例原则分析，麦德公司的违反许可和环境法规的行为是非常轻微的，没有达到墨西哥所述损害生态平衡或保护环境那么严重，因此不应该被拒绝续期许可证和关闭填埋场。最后仲裁庭认定墨西哥该行为构成间接征收，应予以赔偿麦德公司 5533017.12 美元。第三种方法是直接将东道国以公共福利目的实施的非歧视管制措施排除在间接征收范围之外。如前文提到的“Methanex Corporation v. United States of America 案”，仲裁庭就认为东道国做出相关的管制措施是基于公共目的，同时也未在投资者投资前对其做出具体承诺，因此东道国行为不构成间接征收。

3. 投资者应对气候变化义务条款缺失

从历史上看，国际投资协定对环境、气候变化和一般公共利益问题视而不见，因为投资条约核心的利润最大化理念与应对气候变化所体现的公共利益相冲突。[46]有些投资条约条款确定了缔约方管理环境事务的权力，但该类条款通常是范围模糊的原则性或框架性规定[47]。国际投资条约对于投资者的义务规定一般以要求投资者遵守东道国方国内法律，并未在投资条约中具体明确投资者在东道国投资时应对气候变化的义务。如前所述，国际投资条约主要侧重于促进国际投资的发展，因此在具体条约的设定上，也大多以增加投资者权利限制东道国自由为典型，最惠国待遇、国民待遇、公平公正待遇等都是投资者的投资权利，目的在于最大化的赋予投资者最大化的投资自由。通篇的投资者权利而无相对应的义务予以约束，造成投资者肆意妄为，利用投资条约挑战缔约国国内公共管制的权力。2017 年的《泛非投资法典》（PAIC）突破了以前国际投资条约的缺陷，其在第四章专门规定了投资者义务，并载有六条款项，一改之前投资者义务隐于其他条款之

[46]see Akinkugbe Olabisi D & Adebayo Majekolagbe, *International Investment Law and Climate Justice: The Search for a Just Green Investment Order,* 46 Fordham International Law Journal 2,15(2023),

[47] See Beharry Christina & ,Melinda E. Kuritzky, *Going Green: Managing The Environment Through International Investment Arbitration,* 30 American University International Law Review 383,391 (2015).

中国知网 https://www.cnki.net

内默默无闻局面。“(1) 公司治理框架方面，PAIC 规定投资者必须遵守相关行业的国家和国际公司治理标准，以及遵守透明度和会计准则; (2) 社会政治义务方面，投资者必须遵守的社会政治义务，包括尊重文化价值、不干涉内政以及不干涉政府间关系等; (3) 有关贿赂和反腐败方面，PAIC 一般禁止任何贿赂行为; (4) 企业社会责任方面，投资者应为经济、社会和环境进步做出贡献，以期实现东道国的可持续发展; (5) 使用自然资源相关的义务方面，投资者不得以损害东道国的权利和利益的方式进行开发或使用，应该尊重当地居民的权利以及避免与当地社区争夺土地; (6) 商业道德和人权方面，投资者在执行投资时应遵守商业道德和人权的原则，消除一切形式的强迫和强制劳动，包括有效废除童工，或消除就业和职业方面的歧视。” 2023 年 1 月份，非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）公布了投资议定书（以下简称“议定书”）。对比 PAIC，议定书在气候变化问题上更进一步，在第四章可持续发展问题上第 26 条投资和气候变化条款规定缔约国对气候变化问题的职责，在该条款下又列举六点具体权利义务。议定书第五章投资者义务独立成章，第 34 条环境保护条款“1. 投资者及其投资在进行经营活动时，应当尊重和保护环境，尤其应: (a) 尊重享有清洁、健康和可持续环境的权利，如《非洲人权和人民权利宪章》第 24 条和联合国大会第 A/RES/76/300 号决议所规定的权利（享有清洁、健康和可持续环境的人权） (b) 在进行投资活动时应遵守预防和预测原则，对经营活动的任何重大环境危害风险进行预防和预测; (c) 按照最佳国际标准和惯例以及国内法的要求对环境影响进行评价; (d) 将预防原则应用于其环境影响评估和就拟议的投资作出的决定，包括任何必要的减轻或替代投资方法，或排除必要投资; (e) 其经营活动对环境造成或可能造成危害的，采取措施减轻危害，恢复受影响的地点，并确保清洁，健康和可持续发展的环境。2. 投资者不得开发或使用自然资源，损害其权利和利益东道国和当地社区的利益。” 对投资者应对气候变化的义务予以明确，两款六项列举投资者保护环境的具体义务。但遗憾的是，即使上述条约专门规定投资者义务，甚至对环境保护义务进行了独立约定，也仍未见任何气候变化字眼。环境和可持续发展虽然可以解释道包含气候变化问题，但是气候变化作为如此特殊的环境问题，理应有自己的独立之地，这样在具体适用中方可减少歧义。总体而言，投资条约对于投资者应对气候变化的义务还未予以明确规定，这对于未来投资条约的具体适用以及相关投资争议发生时，给东道国应对气候变化措施的合法性留下太多不确定性。

（二）国际投资仲裁庭对气候变化问题裁决失衡

国际投资仲裁是国际投资条约承诺的“牙齿”[48]。国际投资条约设立的国际

[48] 徐树：《国际投资仲裁中滥诉防范机制的构建》，载《法学》2017 年第 5 期，第 152 页。

中国知网 https://www.cnki.net

投资争端解决条款使投资者能够直接对国家提起仲裁，并且不需要东道国的另行同意，该条款默示在东道国进行签署投资条约时就对未来产生的所有投资争议都同意投资者向国际投资仲裁庭提起仲裁。争端解决条款大部分也未设定适用前提，在争端出现时，投资者可以直接根据争端解决条款提起仲裁。投资争端解决机制的便利使近年来投资条约无不规定投资争端条款，把 ISDS 机制作为解决投资者与东道国投资争端的主要方式。从仲裁庭肆意扩大管辖权，到裁决一致性的缺失；从仲裁员独立性、公正性，再到投资者的滥诉。[49]近年来投资仲裁庭不断出现的问题引发了人们的思考，甚至对其合法性产生了质疑。

国际社会一直以来都存在着 ISDS 机制为保护投资者私人利益而牺牲东道国公共利益的批评，这一批评在有关气候变化领域上更是常见。如前所诉“Metalclad Corporation v. the United Mexican States 案”[50]，尽管墨西哥一再强调自身是出于保护公共利益和应对气候变化等目的做出的合法管制，但仲裁庭还是认定只要存在损害就构成间接征收，最后裁决墨西哥承担赔偿，仲裁结果一出，墨西哥国内一片哗然。以往持这种观点的大多数是经济较差的发展中国家，但随着发达国家被诉的案件也越来越多，发达国家的态度也开始发生了转变。投资仲裁制度设立是为了便利的解决投资者与东道国之间的投资争议，因此一般该制度独立于东道国国内司法体系，投资者可以直接于仲裁庭提起仲裁，因此在发生争议时，投资者往往求助投资仲裁庭，忽视东道国国内司法程序，导致东道国国内救济措施施展无门。但现实中，投资仲裁往往需要巨大的时间和金钱成本，往往需要耗费巨大的人力物力，使东道国和投资者二者之间额外支出许多成本，增加负担。许多案件，未必非要走上国际投资仲裁这条道，有时东道国国内程序就可以解决，并且因案件涉及的证据证人就在东道国所在地，采取当地国内程序或许能更简洁。现行 ISDS 当事方可以自行指定仲裁员，通过仲裁员影响裁决，每个仲裁庭都具有临时性质，一案一庭，仲裁庭人员的指定也具有随机性从而导致人员素质也参差不齐。国际投资仲裁庭没有遵循先例的硬性规定，且 ICSID 公约第 53 条明确规定仲裁庭的裁决只限制当事人双方。仲裁庭根据当事人的具体情况适用不同的投资条约并做出不同的解释，因此裁决往往呈现多样化甚至前后矛盾。[51]尽管在理论上，利用仲裁地法院或者 ICSID 内设的撤销机制可以对不当的裁决进行矫正，但在实践中最后真正得到撤销的裁决十分少见，比如不构成法律适用错误或程序滥用的不合理裁决就无法予以矫正。同时现行 ISDS 机制本身就存在程序冗

[49] 曹兴国：《国际投资仲裁制度变革的中国应对——基于宏观视角的动因分析、立场厘定与路径举措》，载《社会科学辑刊》2018 年第 4 期，第 127 页。

[50] Metalclad Corporation v. United Mexican States ,ICSID Case No. ARB(AF)/97/1.

[51] See Boute Anatole, *Combating Climate Change through Investment Arbitration*, 35 Fordham International Law Journal 613,620(2012).

中国知网 https://www.cnki.net

长、费用过于昂贵和透明度不高等缺点。对于许多发展中国家来说，应诉需要承担的成本和律师费就是一个沉重的负担，更不必说是败诉后的赔偿金额。据目前有关气候变化问题的投资争议来看，多数仲裁庭在做出仲裁裁决时，还尚未考虑东道国行为的动机，并未将气候变化相关因素纳入考虑，要么避开不提，要么不将应对气候变化作为东道国行为合法化的理由。

中国知网 https://www.cnki.net

三、国际投资条约应对气候变化问题的改进措施

现有国际投资条约对缔约国应对气候变化更多是起着一个消极作用。越来越多的 ISDS 案例对东道国采取的应对气候变化措施提出质疑，这些措施主要涉及燃煤发电厂淘汰期间提供的补偿，或拒绝或撤销石油和天然气勘探和开采活动许可证的决定，国际投资条约制度导致各国应对气候变化措施增加 ISDS 支出，使向低碳经过渡变得过于昂贵。[52]但若设计得当，国际投资条约是可以引导投资者进行气候友好型投资，促进高新技术跨境流动，抑制气候变化。国际投资条约作为国际主体间就投资关系签订的条约，条约中的权利义务直接影响着投资实践，起着一个导向作用。现有的国际投资条约因历史原因等因素导致其过于侧重经济发展，过于偏向保护投资者利益而忽视东道国利益、忽视气候变化，因此造成投资条约被投资者滥用而损害东道国合法利益。国际投资条约的更新换代不是一蹴而就的，为解决应对气候变化与国际投资条约的矛盾，对现有国际投资条约进行改革，经研究表明，经过改革的国际投资条约可以有效的为各国提供更多的政策空间，促进东道国采取措施应对气候变化。[53]如在国际投资条约中加入气候变化因素考量，使其“绿”化，明确投资者和东道国保护气候变化的权利和义务，同时明确条约的适用范围，那么其将直接促进国际投资向气候变化友好型转型，提升全球应对气候变化水平。

（一）国际投资条约明确回应气候变化问题

1. 序言写明投资条约应回应气候变化问题

如前所述，序言的作用在条约中不可忽视。尤其是在国际投资条约这种多数实体条款约定不明，范围宽广，需要经常做出条约解释的国际条约，序言起到一个奠定条约基调的作用。在国际投资条约序言中明确把应对气候变化作为条约宗旨和条约目标时，整体的国际投资条约便有了一个“绿色”基调，在序言中就告示投资者在国际投资需要采取措施应对气候变化，表明缔约双方的态度与决心，同时明确应对气候变化的条约宗旨和目标后，对仲裁庭进行条约解释也有约束力。

[52] See Paine Joshua & Elizabeth Sheargold, *A Climate Change Carve-Out for Investment Treaties*, 26 Joural of International Economic Law 285,300(2023).

[53] See Sandrine Maljean-Dubois, Helene Ruiz Fabri & Stephan W. Schill, *International Investment Law and Climate Change: Introduction to the Special Issue,* 23 Journal of World 735,741(2022).

中国知网 https://www.cnki.net

之前的投资条约序言过于侧重保护和促进投资，因此导致在面临保护投资和应对气候变化问题起冲突时，仲裁庭不得不偏向投资者，而在序言中明确应对气候变化的宗旨后，仲裁庭做条约解释时，就不能不将气候变化纳入条约解释的考量因素。以后投资条约序言的设计，笔者建议可以借鉴中欧全面投资协定（中欧 CAI）的序言，中欧 CAI 序言规定“决心根据可持续发展的目标加强经济、贸易和投资的关系，并以支持高度保护环境和劳工权利的方式促进投资，包括应对气候变化和强迫劳动，同时考虑到相关国际标准和协定；”首先，中欧 CAI 在序言里表达条约宗旨和目标时，明确以文字形式书面写明应对气候变化，而不是像之前的条约中，采用“保护环境”“可持续发展为目标”这种过于宽泛的表述。气候变化作为环境保护的一种特别领域，其有自身的特性，尤其是“共同但有区别原则”往往与国际投资条约中的国民待遇和最惠国待遇等非歧视待遇相冲突而易被仲裁。其次，中欧 CAI 序言还提及到考虑其他相关国际标准和协定，这一举措有利于减少国际投资条约和其他条约之间的冲突和矛盾。在序言中规定遵守 UNFCC 公约、《京都议定书》以及《巴黎协定》等义务，这不仅有助于加强国际投资协定抑制气候变化的目的，而且还可以避免条约文本意思理解和解释上的不确定性，规避投资者对合理的管制措施提起仲裁[54]。序言不光要明确应对气候变化作为条约宗旨和目标，并且要明确作为条约价值的最高位阶。国际投资条约所体现的价值不是单一的，而是有众多价值的综合体，像现在的序言中所体现的投资保护和可持续发展就是表明该投资条约可持续发展和促进投资都是该条约的价值取向。但在实务二者发生冲突时，仲裁员根据条约解释往往做出保护投资在先的价值取向，而在以后中，为了促进东道国和投资者采取措施应对气候变化，建议在序言中直接明示国际投资条约应对气候变化的最高价值取向，即其他一切活动不得解释为可以对抗应对气候变化的措施，除非以应对气候变化名义实施歧视行为，这样才能确保应对气候变化措施得到真正的落实。同时对于这类条约宜采取开放式例举的方式，有关应对气候变化的国际条约仍在不断的缔结，在序言中采取开放式例举的方式写明投资者投资需遵循该类条约义务，可以增强此类条约的实施，并且缓解现在面临的有关气候变化条约和国际投资条约两类国际条约冲突的现状。

2. 完善东道国实体义务条款

（1）国民待遇

国民待遇条款主张成功与否取决于是否可以构成“like circumstances”（类似

[54] 黄世席：《全球气候变化治理与国际投资法的应对》，载《国际法研究》2017 年第 2 期，第 22 页。

中国知网 https://www.cnki.net

情形），但现有的国际投资条约并没有对该术语做出指导[55]。外资能否享受国民待遇主要是能否与内资处于上述所说“相似情形”，由于国际投资条约的实体规定模糊，仲裁庭在确定的比较对象呈现出较大的差异性，导致进一步使“相似情形”的认定模糊不清。究其原因，是因为国民待遇条款本身没有阐释清楚“相似标准”的认定标准，由此导致了仲裁庭肆无忌惮的解释。[56]近几年，各国普遍注意到该问题，并在条约中对“类似情形”进行了进一步的限定和明确，以期限制仲裁庭的自由裁量权。如《东盟-印度投资协定》（ASEAN-India 投资协定）第 3（4）条“根据具体情况对所有情况进行客观评估，确定投资或投资者是否处于‘类似情况’，包括(a)投资者所在的部门;(b)投资地点;(c)有关措施的目的;(d)一般适用于有关措施的监管程序。审查不应局限于或偏向任何因素。”以及 TPP 的“国民待遇”条款中规定，进行起诉的投资者必须与国内投资者存在竞争关系。这一规定意味着，对于“相似情形”的判断也需满足竞争关系条件。为此，笔者建议，国际投资条约对于“类似情形”的规定，应该采取正面列举式清单进行详细例举，参考 ASEAN-India 投资协定和 TPP 做法，细化其适用标准。同时为达应对气候变化之目的，在类似情形中应该纳入气候变化的例外规定，规定东道国为应对气候变化之目的给予国内投资者特殊待遇或优惠属于类似情形的例外。对于国民待遇的不断扩张的趋势，笔者认为，东道国对于国民待遇适用的范围应结合国内实际情况谨慎考虑，不可一昧的追求国际潮流，在自身法制善不健全或者没能做好准备的前提下把国民待遇一律提前到投资准入前。东道国可以根据本国实际需要制定相应的法律规范或政策来确定本国的国民待遇原则，并以清单或其他方式来认定“相似情形”的存在和例外规则，其他国家无权干涉[57]。因此，为了保护自身公共规制权，在自身法制还没能做好充足准备，极易被诉的情况下，建议暂时保持国民待遇适用范围不扩张，仍然国民待遇只适用于投资准入后。同时，为了提防非气候友好型外国投资者利用国民待遇搭乘气候友好型投资的便车。国际投资条约应该根据碳排放量、使用的能源、原材料等对投资进行区分，区分为气候友好型投资或非气候友好型投资。而针对该二者明确规定给予不同的区别待遇，规定不能因为给予了气候友好型投资更优惠的待遇就被认定构成违反国民待遇。先礼后兵，减少东道国因为实施应对气候变化给予的特别优惠待遇而被仲裁的机率。

---

[55] See Wilensky Meredith, *Reconciling International Investment Law and Climate Change Policy: Potential Liability for Climate Measures Under the Trans-Pacific Partnership*, 45 Environmental Law Reporter 10683 (2015).

[56] 闫旭：《国际投资协定中国民待遇原则的扩张与限制适用问题研究》，载《未来与发展》2021 年第 4 期，第 73 页。

[57] 王亚男：《国民待遇原则中“相似情形”的判定于考量》，载《中国海商法研究》2021 年第 4 期，第 25 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）最惠国待遇

为了避免仲裁庭对最惠国待遇的肆意解释，防止其被投资者滥用从而威胁东道国为应对气候变化采取合理规制，最有效的方法就是通过对国际投资条约进行改革，对最惠国待遇条款做出具体明确的限定。首先是明确最惠国待遇的构成要素，对“相似情形”进行限定，纳入气候变化因素。考量因素越多，意味着对“相似情形”的要求越高，启动最惠国条款的难度就越大。[58]明确规定对于东道国基于应对气候变化考虑给予一国投资者的优惠政策，除非对方投资跟该投资同属于“类似情形”对应对气候变化有特殊贡献，否则不能援引最惠国待遇条款要求享有同等优惠待遇，且东道国以不构成“类似情形”予以拒绝给予同等待遇时也不构成违反最惠国待遇条款，不用承担相应的赔偿责任。同时，针对最惠国待遇条款可以增加特定的应对气候变化例外。比如可以参考 2016 年《斯洛伐克-伊朗双边投资条约》将追求合法公共目标采取的相关措施作为最惠国待遇条款的适用例外，包括保护健康、安全和环境采取的措施、为了国内外公认的劳工权利采取的措施、为了消除贿赂、腐败采取的措施。相关国际投资条约可以直接规定，东道国为了应对气候变化所采取的相关措施，作为最惠国待遇条款适用的例外，增加这一适用例外作为兜底条款，从具体正面适用情形和例外排除适用两方面做出规定，最大程度的维护东道国实施应对气候变化的公共规制权。

为了促进投资条约更好的更新换代，防止条约缔约方利用投资条约中最惠国待遇条款无休止的援引先前或者其他第三方条约中的实体条款或程序性条款，从而导致新条约无法正常得到实施，应该在投资条约中关于最惠国待遇条款的适用范围做出明确规定。联合国贸易与发展会议较早的提出了限制或排除援引第三方条约的解决方法，即明确规定最惠国待遇条款义务不适用于第三方条约实体义务，或者规定最惠国待遇义务不影响基础条约条款。[59]而对于程序条款，随着仲裁庭对个案中的最惠国待遇层出不穷的诡辩解释，使得最惠国待遇条款从一个“无害”的条款发展成为投资者进行“条约挑选”的工具。[60]国际投资仲裁机制的“碎片化”和本身的缺陷助长了国际投资条约的“条约挑选”，东道国在不同投资条约规定的不同争端解决方式都成为了投资者挑选的对象。[61]为防止缔约国出现挑选程序条款出现的情形，宜在条约中写明，除非是当事国之间明确约定的，否则不可以借助最惠国待遇条款引用其他第三方条约中规定而基础条约中没有的争端

[58] 张金矜：《论最惠国待遇条款适用于投资实体待遇的限制性发展趋势》，载《国际经贸探索》2019 年第 5 期，第 106 页。

[59] 王彦志：《从程序到实体：国际投资协定最惠国待遇适用范围的新争议》，载《清华法学》2020 年第 5 期，第 202 页。

[60] 梁丹妮：《国际投资条约最惠国待遇条款适用问题研究——以“伊佳兰公司诉中国案”为中心的分析》，载《法商研究》2012 年第 2 期，第 102 页。

[61] 王燕：《欧盟新一代投资协定“反条约挑选”机制的改革——以 CETA 和 JEEPA 为分析对象》，载《现代法学》2018 年第 3 期，第 166 页。

中国知网 https://www.cnki.net

解决程序性条款。同时笔者建议在时际法层面上限制最惠国条款适用的效果，明确最惠国待遇条款不适用于生效前签订的国际投资中的相关待遇，那么将更直截了当的限制最惠国待遇条款滥用的情形。加拿大与布基纳法索于 2015 年签订的《促进和投资保护协定》就明确指出该协定中的最惠国待遇条款就不适用于协定生效前已经生效或签订的所有双边或者多边协定中约定的待遇，该种做法将极大的符合现在国际投资条约更新换代的需求，能较大程度割裂新旧条款之间的藕断丝连。

（3）公平公正待遇

作为国际投资条约中的帝王条款，公平公正待遇主要是因其自身表述的模糊性才得以被投资者利用。近年来仲裁庭基本认为公平公正的解释要素包括：不得拒绝司法、保护合理期待、非专断与非歧视待遇、透明度要求、提供稳定和可预见的法律框架以及免受东道国的威胁和骚扰。[62]我们可以从以上角度为切入点，对公共公正待遇条款进行进一步完善，使其更贴切现在气候变化下人类社会对其的现实使用需求。对于具体的适用范围上，可以采取封闭式例举清单的进路，将目前既有成熟的公平公正具体义务范畴全部明确列举并纳入清单，并将公平公正待遇条款未来继续演进的掌控权置于缔约方手中，是最可取的发展进路。[63]在清单中，明确投资者保护气候变化的义务，即在投资中，投资者有义务进行气候变化友好型投资，保护东道国当地气候。东道国应对气候变化所采取的相关措施不得以违反公平公正待遇条款被投资者仲裁。而对于合理期待方面，除非是东道国在投资前对投资者做了明确具体的承诺，且投资者根据这一期待做出了投资行为。[64]否则为应对气候变化或者其他公共利益而采取的相关措施不属于不符投资者的合理期待而违反公平公正待遇。而对于充分保护和安全问题，缔约方根据国际投资条约承诺的对投资者进行的充分保护和安全问题的任何承诺仅限于人身安全有关的义务。[65]因此对于东道国采取的其他有关应对气候变化措施而影响投资者相关利益的，投资者不得主张东道国未尽到充分保护和安全义务。同时对于东

[62] 林燕萍，朱钥：《论国际投资协定中的公平公正待遇——以国际投资仲裁实践为视角》，载《上海对外经贸大学学报》2020 年第 3 期，第 73 页。

[63] 王彦志：《国际投资法上公平与公正待遇条款改革的列举清单进路》，载《当代法学》2015 年第 6 期，第 157 页。

[64] See Boute Anatole, *The Potential Contribution of International Investment Protection Law to Combat Climate Change,* 27 Journal of Energy & Natural Resources Law 333(2009).

[65] Paula Henin, et al., *Innovating International Investment Agreements: A Proposed Green Investment Protocol for Climate Change Mitigation and Adaptation*, 36 Journal of International Arbitration 37,40 (2019).

中国知网 https://www.cnki.net

道国的法律框架的的稳定和可预见问题，不能简单的认定东道国缔约之后其法律不能做出任何改变，尤其是现在气候变化如此强烈，东道国为应对气候变化肯定会涉及到本国法律法规的修改，这些应该是投资者在投资时应当予以预见的。对于学者主张的以国际最低待遇标准来解释公平公正待遇原则，笔者赞同徐崇利的主张。即不能搬用抽象的“国际最低待遇标准”来诠解公平与公正待遇，抽象的“国际最低待遇标准”内容笼统，含义模糊，究竟何指，没有定数。对于该项待遇标准，就连西方学者本身也是众说纷纭，莫衷一是。采用如此抽象的标准，为国际仲裁庭滥用自由裁量权，进行“法官造法”大开方便之门。[66]因此公平公正待遇条款是一个独立条款，与国际最低待遇标准没有联系，其有自身独立的适用标准，不能以国际最低标准作为衡量是否违反公平公正待遇。而如何确认公平公正待遇的适用标准，就如上所述依赖于缔约国之间的具体协商，采取封闭式列举清单的模式对具体适用予以明确规定，最后将解释权掌握在缔约国自身手中，明确其有权对适用范围根据具体情形进行解释与补充。

（4）征收条款

对于征收条款，最有效的方法就是在国际投资条约中关于征收条款中直接规定：“东道国为应对气候变化或为其他公共目标采取的措施而对投资者相关财产利益造成的损失不构成间接征收，除非投资者能证明该措施是歧视的、针对性的并且是非必要的且有其他可替代性措施而东道国故意为之的。”但值得注意的是东道国为履行应对气候变化的国际义务采取措施，对不同类别的投资者和投资例如针对气候友好型和非气候友好型投资的投资者和投资本身就是区别对待的，不能仅以表明的区别对待而认为构成歧视，这一点需征收条款中予以明确规定。即规定东道国为应对气候变化而对不同类别的投资或投资者给予不同的待遇时不能被认定构成歧视，从而被认定为存在间接征收。国际投资条约文本上的明确规定，将有效限制投资者肆意借间接征收条款提起仲裁，同时也限制了仲裁庭的自由裁量权，使其不能任意解释征收条款，改变以往仲裁结果多样混乱的局面。

3. 明确投资者应对气候变化义务

以往过于重视投资保护的投资条约是对东道国应对气候变化起阻碍的重要原因，为了使东道国能更好的履行应对气候变化的义务，从权利义务角度出发，必须对投资者的应对气候变化义务加以明确，使以往国际投资条约投资者权利义务过度失衡的天平予以重新得以平衡。摩洛哥双边投资条约 2019 范本（以下简称“2019 范本”）在第三章投资者和投资的义务与责任中就对投资者应对气候变化的义务进行了约定。“2019 范本”第 20.4 条规定“投资者应遵守有关人权

[66] 徐崇利：《公平公正待遇标准：国际投资法中的“帝王条款”？》，载《当代法学》2008 年第 5 期，第 132 页。

中国知网 https://www.cnki.net

和劳工权利、负责任的商业行为、健康和环境保护的国际义务，并符合减缓和适应气候变化的目标，管理或经营其投资。”就明确了投资者应对气候变化义务。笔者认为，以后新一代的国际投资条约对于投资者的应对气候变化义务应该借鉴摩洛哥 2019 范本做法在投资条约中设立专门章节予以规定，除了规定遵守东道国当地法律这样笼统的义务外，对义务予以明确具体。明确规定投资者有减少投资所在地气候变化的义务，需要遵守东道国经国内合法程序制定的有关应对气候变化的政策法规。遵守投资者的义务是投资者享有投资保护权利的前提，在投资者违反相关应对气候变化义务而被东道国制裁或者承受其他责任时，无权主张投资条约中规定的投资者保护权利，如最惠国待遇、国民待遇或者提起仲裁而要求东道国对其损失予以赔偿的各项权利。投资者或投资行为在不同国家面临的法律和激励措施是不同的，从理论上讲，每个主权国家会根据其自身对可持续发展做出的国际承诺，取消对非可持续发展投资的优惠待遇，并以符合该国家独特情况和优先事项的方式加强对此类投资影响的监管保护。[67]因此从权利义务角度来讲，投资条约专设投资者投资义务章节的同时，也应设利东道国政策规制权，在投资条约中重申东道国有权根据国内情况采取相应的措施应对气候变化。只要该措施是非歧视的，是根据国内合法程序并且符合国内法律做出的，投资者就应该予以严格遵守。

（二）纠正国际投资仲裁庭的裁决失衡状态

1.合理要求用尽当地救济途径

国际投资条约中“直通车”性质的仲裁程序不合理的否定了东道国当地救济的地位和作用，忽略了当事方友好协商、投资母国与东道国外协商等方式可能发挥的作用，容易纵容投资者滥诉，对主权国家正常的立法和行政执法造成了威慑和干扰。[68]随着国际投资仲裁案件的暴涨，“直通车”性质的仲裁程序缺陷日益明显，使各国重新思考国际投资仲裁条款的设定。国际投资仲裁在实践中表现出来的过分偏爱投资者、透明度不高、裁决缺乏统一性以及发达国家在投资中身份的转变，导致卡尔沃主义在国际投资领域出现了“回归”的趋势。表现为一些新

---

[67]Martin Brauch Dietrich et al., *Treaty on Sustainable Investment for Climate Change Mitigation and Adaptation: Aligning International Investment Law with the Urgent Need for Climate Change Action,* 36 Journal of International Arbitration 7,12 (2019).

[68] 刘笋：《论国际投资仲裁对国家主权的挑战——兼评美国的应对之策及其启示》，载《法商研究》2008 年第 3 期，第 12 页。

中国知网 https://www.cnki.net

的国际投资条约开始回归东道国的当地司法体系，放弃国际投资仲裁机制，主张用尽当地救济。[69]卡尔沃主义的回归体现东道国对国际投资仲裁条款的的不信任与怀疑，也反映了对本国国内公共规制权的重视。在现实实践中，投资仲裁条款为投资者滥诉东道国大开方便之门，导致东道国为应对气候变化的措施频繁被诉，造成东道国应对气候变化问题的寒蝉效应。因此，有必要对现有的国际投资仲裁条款的“直通车”性质进行限制，充分利用东道国的当地救济途径，最大限度的保护投资者的同时维护东道国为应对气候变化的合法规制权。

国际投资仲裁制度虽说目前有一定的缺陷，但是其保护投资的价值仍然不可忽视，回归到东道国的当地救济并不意味着完全放弃国际投资仲裁制度。而如何处理当地救济途径与国际投资仲裁制度之间的关系，我们可以借鉴参考《美墨加协定》中对于东道国当地救济的要求。美墨加协定规定投资主体在提请仲裁之前，申请人或其代表的当地企业应在东道国适格法院或行政裁决庭启动审理程序。在获得东道国最高层级的终审判决或启动当地救济程序后 30 个月仍未获得终审判决的，方可提请仲裁。同时设置例外情形，在特定部门或者东道国当地救济明显无用时，投资者可以直接提起仲裁。与其同时，《美墨加协定》为消除与用尽当地救济规制之间的冲突采取限缩岔路口条款的方式。在协定附件的 14-D 附录 3 规定，如果投资者已利用东道国当地救济主张权利后，那么就不再享用提起仲裁的权利。为了尽可能的保护东道国采取气候变化保护措施的权利，笔者认为，未来的国际投资仲裁条款可以做出如下规定。一、在投资者以东道国为应对气候变化或其他因维护公共利益而采取的措施违反国际投资条约而要求仲裁时，应先诉诸当地救济程序，只有在获得东道国最高层级的终审判决或者启动当地救济程序满足一定期限仍未获得终审判决时，方可提起仲裁。二、设定岔路口条款，在当地救济程序中，投资者以东道国违反投资条约义务指控时，即丧失提起仲裁的权利。防止投资者滥用仲裁和诉讼权利，造成东道国不必要的成本支出。三、设置例外条款及救济途径。对于投资者寻求当地救济程序明显无效时，可以直接提起仲裁，比如东道国明显消极或者拒绝司法，不保护投资者利益，或者明显偏向东道国，此时寻求当地救济途径无意义或者意义不大。为了防止出现平行程序和双重救济，当投资者一旦提请仲裁时，东道国当地救济程序应立即终止。[70]同时东道国国内救济途径明显违反相关程序性规定导致最后的判决结果明显不公平公正时，投资者在得到最后的裁判结果时仍然有权提起仲裁，而为了保护东道国的国内司法主权，仲裁庭只有程序性审查的权利，无实质内容审查的权利。只有在东道国明显违反程序性规定，仲裁庭方可受理。同时为了保证东道国履行国际投

[69] 王祥修，赵永鹏：《中国与中亚五国双边投资协定 ISDS 条款中的用尽当地救济原则》，载《广西社会科学》2021 年第 11 期，第 95 页。

[70] 宋俊荣：《论投资者——国家间仲裁中的东道国当地救济规则——从〈美墨加协定〉切入》，载《环球法律评论》2021 年第 4 期，第 165 页。

中国知网 https://www.cnki.net

资条约义务，以防以其国内法为由拒绝履行条约义务，因此如果东道国法院给予国内法所作判决处理的措施涉嫌违反国际投资条约，国际仲裁庭仍有权进行复审。[71]

2.国际仲裁庭进行结构性改革

虽说现有的国际投资仲裁庭在针对气候变化问题存在许多不足之处，如偏向投资者不公正的裁决，裁决欠缺统一性导致“同案不同判”，间接阻碍了东道国实施应对气候变化措施。投资仲裁本身虽然存在结构性的缺陷，但并不是不可救药和必须抛弃的，公正性、透明度等问题都可以通过投资仲裁完善模式得到一定程度的解决。而且，投资仲裁完善模式仍然是国际投资争端解决机制改革的主流实践。[72]在管辖权上。鉴于国际投资仲裁机制对气候友好型投资的态度仍然不明朗，为了保护东道国应对气候变化的规制权，以后的国际投资条约可以在争端解决程序中将非气候友好型投资争端排除在管辖权范围外，使这类争端归于东道国法院内部司法程序予以解决，这或许会对应对气候变化更加有利。[73]对于气候友好型投资，允许投资者向仲裁庭提起仲裁，但为了保护东道国国家利益，应提升仲裁的透明度，将案件相关情况及时公开，同时允许除当事人外，与案件相关的厉害关系人参与，仲裁庭主动接受公共监督，从而促使自己公正裁判。对于仲裁庭在条约的适用上，处理好投资条约与气候变化条约之间的冲突尤为关键。气候变化属于环境保护的的重要领域，并且从人权的角度来看，气候变化问题属于集体人权，因此气候变化有关条约效力应高于投资条约。[74]因此，在仲裁庭庭审过程中的条约适用上，当气候变化有关条约与投资条约发生冲突时，仲裁庭应优先适用气候变化有关条约。为增加投资仲裁的连贯性和使不当仲裁得到有效的纠正，应该在着手设立仲裁庭的上诉机构，并在条件成熟时设立常设仲裁法院。现有有关气候变化的投资争端裁决的不公正与肆意偏向投资者，与仲裁人员的的欠缺专业素养能力有着千丝万缕的联系，在投资仲裁人员的挑选上，应该选用对气候变化问题熟悉的专业人员，解决气候变化相关的投资争端，需要掌握专业的技术知识。[75]选用相关的专业仲裁员才能够发挥专业核心作用，最大限度的保证裁决的

[71] 宋俊荣：《论投资者——国家间仲裁中的东道国当地救济规则——从〈美墨加协定〉切入》，载《环球法律评论》2021 年第 4 期，第 167 页。

[72] 王彦志：《国际投资争端解决机制改革的多元模式与中国选择》，载《中南大学学报（社会科学版）》2019 年第 4 期，第 79 页。

[73] 刘雪芹 黄世席：《国家气候变化友好型投资争端的解决与国家安全例外抗辩》，载《新疆社会科学》2022 年第 3 期，第 120 页。

[74] 李坤海：《投资仲裁中协调气候变化投资与东道国气候变化保护冲突的困境与对策》，载《大连海事大学学报（社会科学版）》2021 年第 6 期，第 72 页。

[75] Magraw Daniel et al., *Model Green Investment Treaty: International Investment and Climate Change,* 36 Journal of International Arbitration 95,99 (2019).

中国知网 https://www.cnki.net

公平公正和准确性，使裁决更有说服力。

中国知网 https://www.cnki.net

结语

气候变化日益明显的今天，国际社会为缓解及应对气候变化做出了许多努力，如缔结了《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》、《巴黎公约》等国际条约。但令人遗憾的是，上述条约缔结之后并未得到很好的实施与履行，从国际投资角度来看，东道国在履行上述条约时往往被投资者以违反投资条约而被提起仲裁，同时仲裁庭也往往做出偏向投资者方的仲裁裁决，裁决东道国对投资者进行赔偿。如此往来，东道国为了避免承担巨大的赔偿责任而对气候变化相关条约不愿也不敢遵守，使缓解气候变化的目标得以缓慢实现。有关气候变化的国际条约为何得不到有效实施，东道国采取措施应对气候变化时为何频繁被仲裁？究其原因，是国际投资条约和有关气候变化条约二者之间存在适用上的冲突，正是国际投资条约过于重视国际投资保护而忽视气候变化所导致的。在具体条款上，国民待遇、最惠国待遇、公平公正待遇、征收条款等范围过于广泛，未能明确应对气候变化，使在仲裁中过程中给予仲裁庭过多的自由裁量权的机会，加上国际投资条约序言传达出来的倾斜保护投资者的精神，往往还没开始仲裁就暗示了东道国败诉的局面。在程序上，投资仲裁最近也浮现出各种缺点，如欠缺透明度、过于讨好投资者无法公正裁判、错误仲裁无法得到有效纠正等问题也加重了应对气候变化和保护投资者二者之间的矛盾。但气候变化日益严重，造成的损失也在不断增加，如果再不积极采取措施予以应对气候变化，那必定影响到人类社会的长远发展。因此，我们应解决好两种条约之间的冲突，使气候变化有关条约得到有效实施。归根结底，冲突的根源是国际投资条约无法适应气候变化现实问题所引发的，早期的国际投资条约以发展为唯一目标，自然忽视了气候变化问题，现在气候日益严重下，国际投资条约应适应时代发展，进行更新换代。对此，应该从实体和程序两方面修改完善国际投资协定。在实体上，首先在条约序言中就明确应对气候变化的目标，优先确定条约的绿色基调。在具体的条款中，应考虑气候变化因素，明确投资者应对气候变化的义务和重申东道国应对气候变化采取措施的权利。对于近几年抨击的范围过于宽泛，用词模糊而引发投资者滥用的国民待遇、最惠国待遇、公平公正待遇、和征收条款等，建议明确适用范围，并且在相关规则中明确应对气候变化。在程序上，对国际投资仲裁制度进行相应的改革，增加透明度、建立上诉制度和常设仲裁法庭，从源头改变以往过于倾斜投资者而忽视气候变化的不良风气。总而言之，现有的国际投资条约已经不能适应气候变化，旧条约过于侧重保护投资的价值取向导致阻碍了东道国实施应对气候变化的措施，为了人类社会的可持续发展，国际投资条约务必需要进行更新换代，纳入

中国知网 https://www.cnki.net

气候变化保护目标，进行“绿色化”发展。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

（一）中文参考文献

1. 艾素君：《晚近国际投资协定对东道国规制权的保障及中国实践》，载《河北法学》2023年第2期。
2. 杜群：《〈巴黎协定〉对气候变化诉讼发展的实证意义》》，载《政治与法律》2022年第7期。
3. 高凛：《〈巴黎协定〉框架下全球气候变化治理机制及前景展望》，载《国际商务研究》2022年第6期。
4. 冯寿波：《论条约序言的法律效力——兼论TRIPS序言与〈WTO协定〉及其涵盖协定之序言间的位阶关系》，载《政治与法律》2013年第8期。
5. 龚柏华：《论境外投资规制中可持续发展理念》，载《政法论坛》2022年第2期。
6. 黄世席：《可持续发展视角下国际投资争端解决机制的革新》，载《当代法学》2016年第2期。
7. 黄世席：《全球气候变化治理与国际投资法的应对》，载《国际法研究》2017年第2期。
8. 韩永红，李明：《欧盟碳排放交易立法的域外适用及中国应对》，载《武大国际法评论》2021年第6期。
9. 胡枚玲：《从美国BIT范本刊国际投资与环境保护之协调》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2016年第1期。
10. 江清云：《环境措施与国际争端解决风险刍议——以瑞典Vattenfall公司诉德国政府为例》，载《河北法学》2014年第11期。
11. 勒也：《投资者——国家争端解决机制改革的路径分化与中国应对策略研究》，载《河北法学》2021年第7期。
12. 林燕萍，朱玥：《论国际投资协定中的公平公正待遇——以国际投资仲裁实践为视角》，载《上海对外经贸大学学报》2020年第3期。
13. 李坤海：《投资仲裁中协调气候变化投资与东道国气候变化保护冲突的困境与对策》，载《大连海事大学学报（社会科学版）》2021年第6期。
14. 李俊然，赵俊娟：《国际投资协定与气候变化协定的冲突与协调——以国际投资协定的实体规则为视角》，载《河北法学》2019年第7期。
15. 李威：《〈从京都议定书〉到〈巴黎协定〉：气候变化国际法的改革与发展》，载《上海对外经贸大学学报》2016年第5期。
16. 梁晓菲：《论〈巴黎协定〉遵约机制：透明度框架与全球盘点》，载《西安交通大学学报（社会科学版）》2018年第2期。
17. 梁丹妮：《国际投资条约最惠国待遇条款适用问题研究——以“伊佳兰公司诉中国案”为中心的分析》，载《法商研究》2012年第2期。

中国知网 https://www.cnki.net

18. 刘雪芹，黄世席：《国际气候变化友好型投资争端的解决与国际安全例外抗辩》，载《新疆社会科学》2022 年第 3 期。
19. 刘万啸：《全球治理视野下环境保护与国际投资体制的冲突和协调》，载《齐鲁学刊》2017 年第 4 期。
20. 刘万啸：《气候变化背景下国际投资规则的发展趋势及我国对策研究》，载《政法论坛》2014 年第 2 期。
21. 刘万啸:《气候变化背景下外国投资者与政府争端的解决——以我国双边投资协定为例》，载《政法论坛》2012 年第 6 期。
22. 刘笋：《论国际投资仲裁对国家主权的挑战——兼评美国的应对之策及其启示》，载《法商研究》2008 年第 3 期。
23. 漆彤，吴放：《论国际投资条约价值多元化之发展趋势》，载《福建江夏学院学报》2014 年第 2 期。
24. 邵莉莉：《碳中和背景下国际碳排放治理的“共同责任”构建——共同但有区别责任的困境及消解》，载《政治与法律》2022 年第 2 期。
25. 宋俊荣：《论投资者——国家间仲裁中的东道国当地救济规则——从〈美墨加协定〉切入》，载《环球法律评论》2021 年第 4 期。
26. 孙承，李建福：《美国气候变化正义：立场变迁与实质辨析》，载《山西大学学报（哲学社会科学版）》2019 年第 2 期。
27. 谭秀杰，齐绍洲：《气候变化政策是否影响了国际投资和国际贸易——京都承诺期碳泄漏实证研究》，载《世界经济贸易》2014 年第 8 期。
28. 王彦志：《从程序到实体：国际投资协定最惠国待遇适用范围的新争议》，载《清华法学》2020 年第 5 期。
29. 王彦志：《国际投资争端解决机制改革的多元模式与中国选择》，载《中南大学学报（社会科学版）》2019 年第 4 期。
30. 王艳冰：《美国新版 BIT 对环境保护的强化及中国对策》，载《上海政法学院学报（法治论坛）》2015 年第 4 期。
31. 王艳冰：《国际投资法实现气候变化正义之理论路径与实践原则》，载《学术界》2013 年第 186 期。
32. 王艳冰：《国际投资法应对气候变化之合法性分析》，载《学术界》2012 年第 165 期。
33. 王艳冰：《气候变化与国际投资法应对》，载《政法论坛》2011 年第 3 期。
34. 王艳冰：《将环境保护纳入国际投资协定的必要性》，载《法治论坛》2009 年第 5 期。
35. 王艳冰：《投资自由背景下的环境保护》，载《法治论坛》2005 年第 2 期。
36. 王燕：《欧盟新一代投资协定“反条约挑选”机制的改革——以 CETA 和 JEEPA 为分析对象》，载《现代法学》2018 年第 3 期。
37. 王效文：《国际投资中环境保护法律问题研究——以〈北美自由贸易协定〉为例》，载《北京邮电大学学报（社会科学版）》2014 年第 5 期。
38. 王祥修，赵永鹏：《中国与中亚五国双边投资协定 ISDS 条款中的用尽当地救济原则》，载《广西社会科学》2021 年第 11 期。
39. 王亚男：《国民待遇原则中“相似情形”的判定与考量》，载《中国海商法研究》2021

中国知网 https://www.cnki.net

年第 4 期。

40. 文洋：《国际投资规则的变化新趋势与中国的应对方略》，载《东北亚论坛》2023 年第 2 期。
41. 魏艳茹：《国际投资协议视野中的气候变化治理》，载《江西社会科学》2021 年第 9 期。
42. 魏庆坡：《美国宣布推出对〈巴黎协定〉遵约机制的启示和完善》，载《国际商务——对外经济贸易大学学报》2020 年第 6 期。
43. 魏庆坡：《后巴黎时代气候变化制度与国际贸易规则的协同研究》，载《河北法学》2019 年第 6 期。
44. 徐崇利：《〈巴黎协定〉制度变迁的性质与中国的推动作用》，载《法制与社会发展》2018 年第 6 期。
45. 徐崇利：《公平公正待遇标准：国际投资法中的“帝王条款”？》，载《现代法学》2008 年第 5 期。
46. 徐崇利：《从实体到程序：最惠国待遇适用范围之争》，载《法商研究》2007 年第 2 期。
47. 闫旭：《论公平公正待遇与最低待遇标准的关系——兼评 RCEP 投资待遇规则》，载《西部法学评论》2022 年第 1 期。
48. 闫旭：《国际投资协定中国民待遇原则的扩张与限制适用问题研究》，载《未来与发展》2021 年第 4 期。
49. 于宏源：《自上而下的全球气候变化治理模式调整：动力、特点与趋势》，载《国际关系研究》2020 年第 1 期。
50. 易卫中：《论后巴黎时代气候变化遵约机制的建构路径及我国的策略》，载《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》2020 年第 2 期。
51. 赵婧：《埃及参与全球气候变化治理：认知、实践与动因》，载《阿拉伯世界研究》2022 年第 6 期。
52. 赵玉意：《气候变化“小多边主义”法治研究》，载《国际经济法学刊》2022 年第 2 期。
53. 朱炳成：《全球气候变化治理面临的挑战及其法制应对》，载《中州学刊》2020 年第 4 期。
54. 张金矜：《论最惠国待遇条款适用于投资实体待遇的限制性发展趋势》，载《国际经贸探索》2019 年第 5 期。
55. 张光：《论东道国的环境措施与间接征收——基于若干国际投资仲裁案例的研究》，载《法学论坛》2016 年第 4 期。
56. 曾华群：《论我国“可持续发展导向”双边投资条约的实践》，载《厦门大学学报(哲学社会科学版）》2015 年第 1 期。
57. 曾华群：《“可持续发展的投资政策框架”与我国的对策》，载《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2013 年第 6 期。

（二）英文参考文献

中国知网 https://www.cnki.net

1. Asselt Hrro Van, Francesco Sindico & Micael A. Mehling, Global Climate Change and the Fragmentation of International Law,30 Law & Policy 423(2008).
2. Akinkugbe OlabisiD & Adebayo Majekolagb, International Investment Law and Climate Justice: The Search for a Just Green Investment Order,46Fordham International Law Journal 169(2023).
3. Aerni Philipp et al. , Climate Change and International Law: Exploring the Linkages between Human Rights, Environment, Trade and Investment,53 German Yearbook of International Law 139(2010).
4. Boute Anatole, Combating Climate Change through Investment Arbitration,35 Fordham International Law Journal 613(2012).
5. Boute Anatole, The Potential Contribution of International Investment Protection Law to Combat Climate Change, 27 Journal of Energy & Natural Resources Law 333 (2009).
6. Beharry Christina L & Melinda E. Kuritzky, Going Green: Managing The Environment Through International Investment Arbitration, 30 American University International Law Review 383 (2015).
7. Brauch Martin Dietrich et al., Treaty on Sustainable Investment for Climate Change Mitigation and Adaptation: Aligning International Investment Law with the Urgent Need for Climate Change Action, 36 Journal of International Arbitration 7 (2019).
8. Baker ShalandaH., Climate Change and International Economic Law,43 Ecology Law Quarterly 53(2016).
9. Condon Bradly J., Climate Change and International Investment Agreements, 14 Chinese Journal of International Law 305 (2015).
10. Dooley Josephine & Canberra,The Co-Existence of Mitigation and International Investment Law: A Practical Assessment of Climate Change Action Under Less 'Green-Friendly' Investment Agreements, 23 Journal of World Investment & Trade 849 (2022).
11. Darcy John,Global Climate Change Law, 2021 Global Environmental Law Annual 7(2021).
12. Eroj Aaron , Climate Change and International Norms, 27 Journal of Land Use &Environment Law 69(2020).
13. Ezroj Aaron, Climate Change And International Norms, 27 Journal of Land Use & Environment Law 69 (2011).
14. Hereher Mohamed E.,Vulnerability of the Nile Delta to Sea Level Rise: An Assessment Using Remote Sensing,Geomatics,1Natural Hazards and Risk 315(2010).
15. Henin Paula et al., Innovating International Investment Agreements: A Proposed Green Investment Protocol for Climate Change Mitigation and Adaptation, 36 Journal of International Arbitration 37 (2019).
16. Kim Dae-Jung, Standards of Protection in Investment Arbitration for Upcoming Introduction Climate Change Cases, 24 Journal of Arbitration Studies 33 (2014).
17. Kotecha Krupa, Pension Fund Investment and Climate Change: A Legal Imperative, 37 Estates, Trusts & Pensions Journal 207(2018).
18. Leal-Arcas Rafael et al., Of International Trade, Climate Change,Investment and A

中国知网 https://www.cnki.net

Prosperous Future, 12 Trade, Law and Development 405 (2020).

19. Magraw Daniel et al., Model Green Investment Treaty: International Investment and Climate Change, 36 Journal of International Arbitration 95 (2019).
20. Megurol Maiko,Litigating Climate Change Through International Law: Obligations Strategy and Rights Strategy,33 Leiden Journal of International Law 933(2020).
21. Maljean-Dubois Sandrine, Helene Ruiz Fabri & Stephan W. Schill, International Investment Law and Climate Change: Introduction to the Special Issue, 23 Journal of World Investment & Trade 735 (2022).
22. Nwankwo Chidebe M.,Balancing International Investment Law and Climate Change in Africa: Assessing Vertical and Horizontal Norms,17 Manchester Journal of International Economic Law 48 (2020).
23. Paine Joshua & Elizabeth Sheargold,A Climate Change Carve-Out for Investment Treaties, 26 Journal of International Economic Law 285(2023).
24. Saul Ben, Climate Change,Conflict and Security: International Law Challenges, 9 New Zealand Armed Forces Law Review 1 (2009).
25. Scanlan Melissa K.,Climate Risk Is Investment Risk, 36 Journal of Environmental Law and Litigation 1(2021).
26. Wilensky Meredith, Reconciling International Investment Law and Climate Change Policy: Potential Liability for Climate Measures Under the Trans-Pacific Partnership, 45 Environmental Law Reporter 10683 (2015).

中国知网 https://www.cnki.net